

一、行政处罚

1. 知识产权民事侵权责任的免除不影响行政责任的承担 1
——某水泥公司诉某市市场监督管理局行政处罚案
2. 行政处罚中没收违法所得应否扣除经营成本 5
——某海鲜摊诉某市场监督管理局、某市人民政府行政处罚案
3. 对责任能力欠缺的行政相对人作出不予处罚决定应通知其法定代理人或监护人陪同 9
——刘某诉某派出所、某区政府不予行政处罚及行政复议案
4. 瞒报生产安全事故属于具有继续状态的违法行为 16
——某公司诉某区应急管理局行政处罚案
5. 美容公司“超范围经营”与其工作人员“无证开展医疗美容服务”同时受到行政处罚不违反“一事不二罚”原则 20
——岳某诉某县卫生健康局行政处罚案
6. 食药同源产品的性质应当结合其主要成分、制作方法、宣传用途等进行综合判定 28
——郑某诉街道办、市政府行政处罚及行政复议案
7. 未明示收集目的、未经同意使用消费者个人信息的行为违法 31
——某公司诉某市市场监督管理局责令改正及罚款案

2 中国法院2025年度案例·行政纠纷

8. 现场即时采样的监测结果可作为判定污染物是否超标的证据	36
——某矿业有限责任公司诉某市河流水生态保护综合执法局罚款案	
9. 行政机关纠正已经生效的行政处罚应当基于正当事由并履行法定程序	40
——刘某某诉某市公安局交通管理局行政处罚案	
10. 营销推广性质的扫码免费赠与商品属于经营行为	44
——某品种盐公司蒙城分公司诉某县市场监督管理局罚款案	
11. 责令停止供气工作函属于行政诉讼受案范围的认定标准	48
——宋某某诉某街道办事处责令停止供气案	
12. 肇事后虽将伤者送至医院，但未接受交通管理部门处理自行离开的应视为交通肇事后逃逸	53
——李某诉某县公安交通警察大队罚款及暂扣许可证件案	
13. 教师对学生实施教育惩戒行为失当违反治安管理处罚法的，公安机关需对其进行治安处罚	57
——张某某诉某市人民政府行政复议案	

二、行政强制执行

14. 违法建筑案件中行政机关与行政相对人混合过错中的信赖利益认定	62
——陈某某诉某县某镇政府强制拆除房屋及行政赔偿案	
15. 已为后续具体行为吸收的前行政强制措施不具有可诉性	69
——郑某诉某区交通大队行政强制措施案	
16. 强制拆除无需等待执行决定救济期限届满即可实施	73
——某公司诉某区执法局强制拆除房屋案	

17. 人民法院应当对已纳入征收范围内的房屋实施的强制拆除行为
进行从严实体审查 77
——杨某诉某区城市管理执法局等强制拆除房屋或设施案
18. 行政机关不得以扣促罚，以相对人未缴纳罚款为由超期扣押财物 80
——罗某诉某镇政府行政强制措施及行政赔偿案
19. 行政机关拆除被征收人依协议腾退的房屋不属于行政强制行为 84
——王某某、吴某某诉某县人民政府某街道办事处强制拆除房屋案

三 、 行 政 许 可

20. 农村宅基地审批行政行为对相邻权不产生直接影响，相邻权人
不具有提起行政诉讼的主体资格 89
——李某甲诉某镇政府农村宅基地审批案
21. 行政机关将同一区域内独家特许经营权通过行政许可先后授予
给不同的经营者，先经营者对行政机关重复许可的行政行为有
权提起行政复议 92
——广东某某公司诉某市人民政府特许经营许可案
22. 行政机关通过法律文书送达、短信、网络公告等方式告知行政相
对人拟作出的行政行为，已经充分保障行政相对人的陈述申辩权 96
——刘某诉某车辆管理所、某市交警支队注销机动车驾驶证案
23. 中医医术确有专长人员医师资格考核认定审查标准 100
——韩某某诉某市中医药管理局、国家中医药管理局行政许可及行政复
议案
24. 行政机关在12345热线平台的反馈答复不认定为代表行政机关
作出履职行为 104
——翁某某诉某镇人民政府不履行行政许可职责案

四、行政登记

25. 虚假材料下的简易注销登记应予撤销	108
—— 石某诉某区市场监督管理局工商登记案	
26. 不动产登记机关应当依据生效的征收决定作出不动产注销登记	112
——某货物配载中心诉某市自然资源和规划局行政登记案	
27. 当事人仅以申请材料非本人签字为由申请撤销工商登记的不予支持	118
——宋某某诉某区市场监督管理局、某家具店工商登记案	
28. 房屋登记颁证及换证并非赋权行为，当事人对房屋权属发生争 议的应当通过民事诉讼确定权利归属	123
——环境工程公司诉不动产登记中心房屋所有权登记案	
29. 行政争议以民事争议的解决为基础的，应当告知 一 并解决	127
——徐某甲诉某县行政审批服务局行政登记案	
30. 与具体行政机关不具有利害关系的债权人不具有原告资格	132
——某银行厦门分行与某县自然资源局、某县不动产登记中心房屋所有 权登记案	
31. 约定声明不属“先民后行”情形，缺乏事实基础的转移登记应 予撤销	136
——田某诉某规划和自然资源委员会分局房屋所有权登记案	
32. 外商投资企业办理融资租赁经营范围变更登记应事先取得金融 监督管理部门许可	140
——某投资公司诉上海市市场监督管理局、国家市场监督管理总局行政 登记及行政复议案	

五、行政确认

33. 提供的劳动虽与工作任务相衔接，但不属于本职工作范围，遭受的损害不应认定为工伤 145
——欧某某诉R县人力资源和社会保障局工伤保险资格或者待遇认定案
34. 劳动者参加单位指派的拔河比赛发生伤亡的应认定为工伤 149
——房地产公司诉某区人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案
35. 物业服务企业对业主不动产权登记提起行政诉讼的原告主体资格认定 153
——某物业有限公司诉某市不动产登记局行政确认案
36. 患职业病职工的职业接触史可能涉及多个单位的工伤认定 157
——某石业公司诉某人社局不服认定工伤决定案
37. 诉请要求确认行政行为合法有效并不属于人民法院行政案件受案范围及创造性裁判方式的选择实质解决争议 161
——饶某诉某大学确认毕业证书效力案
38. 未达成补偿协议即强拆，即便事后补偿亦不能阻却拆除行为的违法性 164
——张某某、邱某某诉某开发区管委会确认推平树木行为违法案
39. 未享受职工基本养老保险待遇的超龄劳动者与用人单位构成劳动关系 169
——某县某公司诉某县人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案
- ~40. 与履行工作职责关联度较高的“旧病复发”应认定为工伤 172
——许某某诉某市人力资源和社会保障局工伤认定案
41. 与用人单位存在劳务关系的超龄劳动者不享受工伤保险待遇 176
——李某甲、李某乙诉某市人力资源和社会保障局工伤行政确认案

六、政府信息公开

42. 不能仅以被申请人称信息涉及商业秘密，不同意公开为由不经调查核实直接答复不予公开181
——胡某某诉某住房和城乡建设局政府信息公开案
43. 涉第三方政府信息关涉第三方信息权利时，行政机关须履行书面征求意见程序 185
——丛某某诉某生态环境局政府信息公开案
44. 涉商业秘密政府信息公开前应书面征询第三方意见 189
——柳某某诉某区人民政府办公室政府信息公开案
45. 诉讼过程中被诉行政机关职权变更时适格被告的调整应遵循便宜性和可执行性之标准 194
——金某某诉某区农业农村局政府信息公开案
46. 政府信息不完整不应成为拒绝公开的理由 198
——丁某某诉某区住房和城乡建设局政府信息公开案
47. 政府信息内容的合法性不是政府信息公开案件审理范围202
——钱某某诉某市公安局、某市人民政府政府信息公开及行政复议案

七、行政协议

48. 房屋买卖未办理过户登记时实际居住人可认定为被征收人207
——王某某等诉某镇政府房屋搬迁补偿安置行政协议案
49. 基于“合理信赖”构成表见代理的行政协议有效 212
——石某某诉某县住房和城乡建设局、某县某街道办事处确认行政协议无效案

50. “探求真实合意”是相对人提起行政协议撤销之诉审查的首要标准	217
——某投资公司诉某市自然资源局、某市人民政府行政协议案	
51. 行政机关未按约定履行行政协议纠纷中权利义务确定及裁判 方式的选择	221
——某集团公司诉甲市政府未按约定履行公交化改造行政协议案	
52. 行政相对人起诉解除行政协议的应当适用除斥期间的规定	226
——李某某诉某县房屋征收补偿服务中心解除行政协议案	
53. 行政协议案件中对行政机关合同条款解释的限制及对违约情形 的认定	230
——某技术公司诉某区城市管理和综合执法局行政协议案	
54. 行政协议履行之诉应坚持合法性及合约性双重审查	235
——某教育投资公司诉某市教育局行政协议案	
55. 行政协议效力的确认及对行政机关行使行政优益权行为的合法 性审查问题	240
——戚某甲等诉某街道办事处未按约定履行补偿安置协议案	
56. 预约性行政协议约定的条件成就的行政机关须全面履行协议义务	245
——罗某某诉某镇政府继续履行行政协议案	
57. 征收补偿协议未包含房屋安置事项的，人民法院应当判决行政 机关就安置问题另行作出处理	249
——冯某某诉某街道办行政协议案	
58. 因城中村改造签订的拆迁安置协议应当视具体情况判断是否属 于行政协议	253
——刘某某诉柳州市某区自然资源局等支付补偿款案	

八、行政补偿

59. 地方补偿标准可以作为人民法院审查湿地自然保护区范围内行政补偿是否到位的依据 258
——某种植公司诉某镇人民政府行政补偿案

60. 对动物疫区采取防疫措施造成损失的补偿标准 262
——北京某养殖场诉北京市某区人民政府行政补偿案

61. 征收补偿决定作出时间与评估时点间隔较长是否认定征收补偿决定不合法 267
——沈某诉某区政府房屋征收补偿案

62. 征收主体的补偿安置职责并不因其就在先违法占地行为承担赔偿责任而当然免除 271
——范某某诉T 市人民政府不履行补偿安置职责案

九、其 他

63. 复议机关驳回申请人对重复申诉不予答复行为的申请不具有可诉性 276
——郑某某诉某市某区人民政府驳回行政复议申请决定案

64. 复议机关以未经过纳税前置程序为由作出的程序性驳回决定可诉 280
——沧州某某公司诉某省税务局不予受理行政复议申请案

65. 互联网医院在线开具处方前应当履行审核义务 284
——阳某某诉某区卫生健康局行政处理案

66. 行政机关不得以业主未交纳物业费为由限制其参加业委会竞选 288
——严某某诉某街道办事处行政处理案

67. 市场监督管理机关对于嵌套平台的责任主体认定应以明示公开 为判断标准	292
——周某诉某区市场监督管理局、某区人民政府行政复议案	
68. 已办理退休手续人员，不得再行要求办理保险关系转移接续	297
——班某诉某区社会保险事业管理中心不履行养老保险关系转移职责案	
69. 未依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提 供相应的担保，相对人要求撤销行政复议申请不予受理决定的， 人民法院不予支持	301
——某药业公司诉某市税务局不予受理行政复议申请决定案	
70. 当事人的诉求已通过其他途径予以救济，复议机关是否仍应责 令原行政机关履行法定职责	308
——袁某诉某州人民政府不予受理行政复议申请决定案	
71. 坚持以人民为中心 实质化解赔偿困境	318
——某地区赔偿申请人撤回赔偿申请案	

一、行政处罚

1

知识产权民事侵权责任的免除不影响行政责任的承担

—— 某水泥公司诉某市市场监督管理局行政处罚案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院(2023)桂0804行初7号行政判决书

2. 案由：行政处罚纠纷

3. 当事人

原告：某水泥公司

被告：某市市场监督管理局(以下简称某市市监局)

【基本案情】

某水泥公司持有“名×”商标，核定使用商品/服务第19类，在专用权保护期限内。某水泥公司持有的商标曾被多次授予荣誉。案外人某某公司控股(香港)有限公司(以下简称某公司)经核准注册了“王牌××”商标，核定使用商品/服务第19类建筑用木材、混凝土、石膏、水泥、砖、石棉灰泥等，专用权期限为2018年1月14日至2028年1月13日。某市市监局接到报案线索

后，于2022年4月28日、5月5日，到某水泥公司生产车间进行检查，发现某水泥公司使用印有“王牌××”字样的水泥包装袋，并封存某水泥公司印有“王牌××”字样的包装袋2905条。同年5月，某市市监局到桂平市某亿水泥店进行检查，并对该店经营者进行询问，确认其店内售卖的印有“名×”及“王牌××”等字样的白水泥是其从某水泥公司处购进。后某市市监局还先后询问了某水泥公司的办公室主任兰某良、员工吴某梅。同年6月23日，某市市监局送达行政处罚告知书给某水泥公司，告知拟处罚内容、事实及理由，并告知某水泥公司有权陈述、申辩、要求听证。同年7月22日，某市市监局举行了听证会。同年8月17日，某市市监局作出行政处罚决定书。该处罚决定书已于2022年8月18日送达给某水泥公司。某水泥公司已缴纳罚款150000元。某水泥公司对某市市监局的行政处罚决定不服，于2023年1月28日诉至桂平市人民法院，该院于2023年3月16日开庭审理本案，后于同年4月25日以本案属知识产权行政纠纷为由将本案移送贵港市覃塘区人民法院处理。

【案件焦点】

民事侵权责任的免除是否影响行政责任的承担。

【法院裁判要旨】①

广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院经审理认为：某市市监局作为工商行政管理部门，具有对某水泥公司涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处的法定职责。即使某水泥公司与某公司存在其他商业合作关系，某公司自愿放弃追究某水泥公司的民事责任，也不妨碍某市市监局依法履行法定职责，对本案进行取证调查、作出行政处罚。虽某水泥公司已同时在包装袋上使用了其自有商标，但该使用未起到识别商品来源的作用，不足以避免相关公众的混淆误认。某水泥公司未经某公司的许可，在水泥包装袋正中间使用的“王牌××”字样，字体较大且位置醒目，客观上能起到识别商品来源的

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

作用，易使相关公众对该水泥商品的来源产生误认或者认为其来源与某公司的“王牌××”商标商品有特定联系，构成商标性使用，已侵犯了某公司的“王牌××”商标专用权。某市市监局对某水泥公司的案涉违法行为立案调查后，认定某水泥公司的侵权行为成立，进行了行政处罚告知，召开了听证会，听取了某水泥公司的申辩、陈述后作出的被诉行政处罚决定，证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序，应予维持。某市市监局在作出被诉行政处罚前已就某水泥公司的违法经营额进行了充分调查取证，但因某水泥公司在销售带有“王牌××”字样的白水泥时未作单独登记、统计，导致某市市监局对某水泥公司的违法经营额无法具体计算。庭审中，对于某水泥公司销售带有“王牌××”字样的白水泥所得经营额，双方再次明确表示无法计算。结合某水泥公司的经营情况、销售时间、包装袋数量、已销售情况以及某水泥公司配合调查等情况，某市市监局根据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款的规定，对某水泥公司处以150000元的罚款合法、适当，故法院对某水泥公司的主张不予支持。

广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院判决如下：

驳回原告某水泥公司的全部诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】①

企业作为市场经营主体，应当严格遵守《中华人民共和国商标法》等法律的有关规定，诚信经营，发展其自有品牌、增强其品牌辨识度，共同维护市场秩序。但当其侵害他人合法商标时，应承担相应的法律责任，如赔偿被侵权人所遭受的损失、被处行政处罚，如构成犯罪的还应承担刑事责任。本案中，主要探讨以下问题：侵权人与注册商标权利人就民事侵权责任达成和解后，行政责任如何承担。

①本书【法官后语】对相关法律问题涉及的法律法规等进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

4 中国法院2025年度案例·行政纠纷

一、民事责任、行政责任、刑事责任不可互相替代

《中华人民共和国民法典》第一百八十七条规定：“民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的，承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任；民事主体的财产不足以支付的，优先用于承担民事责任。”《中华人民共和国行政处罚法》第八条规定：“公民、法人或者其他组织因违法行为受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任的，不得以行政处罚代替刑事处罚。”从上述法律规定中，不难看出，民事责任、行政责任以及刑事责任之间不可相互替代，三者之间是并存的关系，只是存在有优先顺序，故同一个当事人基于同一个行为可能会同时产生民事责任、行政责任以及刑事责任，且均应承担，不能因某一责任的免除而主张不承担其他的责任。例如，本案中，虽然侵权人只实施了一个违法行为，即在同类产品中使用了他人的注册商标，违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条的规定，侵犯了他人的商标专用权，同时产生了民事责任和行政责任。民事责任是在侵权人与被侵权人之间产生，是由于侵犯了被侵权人的注册商标，减损了被侵权人的利益，而需停止侵权行为并对因此造成的损失进行赔偿。而行政责任则是在侵权人与行政机关之间产生，行政机关基于《中华人民共和国商标法》第六十条第二款、第六十一条的规定，享有对侵权人侵犯注册商标专用权的行为进行查处、罚款的职权，并根据侵权人的侵权行为进行行政处罚，由此侵权人就产生了行政责任。以上所述的民事责任与行政责任是并存的关系，侵权人均需承担。

二、民事责任与行政责任的区别

在本案中，主要探索的是民事责任与行政责任之间的关系，民事责任主要是对被侵权人权利的恢复，赔偿或补偿被侵权人所受损失，是一种补偿性法律责任，承担责任的方式有赔偿损失、支付违约金、停止侵权、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状以及消除影响和赔礼道歉等，可由双方当事人就具体内容或承担方式进行协商、和解或调解，无须国家机关介入；而行政责任则

是重在维护公共利益和社会秩序，通过行政处罚对侵权人进行惩戒，从而达到减少再次实施违法行为的可能性，主要方式有警告、罚款、行政拘留、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等，是一种惩罚性法律责任，具有强制性。回到本案中，侵权人主张其与被侵权人已经达成和解，被侵权人已经放弃对其进行起诉、主张权利，且没有造成危害性后果，故行政机关不应再对其进行行政处罚。但是根据以上所述，民事责任双方可以自行和解，但行政责任具有惩罚性，目的是对侵权人进行惩戒，避免其再次发生类似行为，维护社会的稳定，具有强制性，系行政机关履行法定职权，故即便侵权人已就民事侵权责任达成和解，仍应承担行政责任，接受因自身违法行为而带来的不利后果。

编写人：广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 廖坤凤

行政处罚中没收违法所得应否扣除经营成本

—— 某海鲜摊诉某市场监督管理局、某市人民政府行政处罚案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区防城港市中级人民法院(2024)桂06行终6号行政判决书

2. 案由：行政处罚纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某海鲜摊

被告(被上诉人): 某市场监督管理局、某市人民政府

【基本案情】

2023年4月30日，某海鲜摊经营者梁某某在某市国贸市场对面杂货摊购买三台电子计价秤；购买后，其对上述三台电子计价秤称重数值进行调试，按按键“数字9+去皮+单价4”可使2000克砝码在秤具上显示为4.8市斤即折算为2400克。

自2023年5月1日开始，某海鲜摊使用上述调试的三台电子计价秤用于称重销售海鲜交易结算。

2023年5月2日，某市场监督管理局执法人员对某海鲜摊进行计量器具检查，发现某海鲜摊所使用的三台电子计价秤分别用2000克标准砝码检测时均显示为4.8市斤即折算为2400克，电子计价秤所显示重量读数与砝码实际重量不相符，且执法人员对摊前挂的微信收款码所关联的手机微信收款记录检查发现，某海鲜摊于2023年5月1日至2日使用上述三台电子秤期间销售海鲜产品共完成474笔，营业额共计90300.1元。某市场监督管理局执法人员认为某海鲜摊的上述行为涉嫌违反《广西壮族自治区计量条例》第十一条第五项的规定，经某市场监督管理局负责人批准于2023年5月2日立案，同时对上述三台电子计价秤采取先行登记保存措施，并送至某市市场监督管理检验监测中心进行计量鉴定。经鉴定，上述三台电子计价秤的计量安全性显示为不符合。

调查终结后，经某市场监督管理局政策法规部的审核机构负责人法制审核及负责人集体讨论，一致同意对某海鲜摊拟作出如下处罚：（1）没收三台电子计价秤；（2）没收违法所得90300.1元；（3）罚款800元。2023年6月6日，某市场监督管理局向某海鲜摊送达《行政处罚告知书》。2023年6月14日，某市场监督管理局向某海鲜摊送达《行政处罚决定书》。

后某海鲜摊不服上述行政处罚决定，向某市人民政府申请行政复议。2023年9月4日，某市人民政府作出《行政复议决定书》，维持某市场监督管理局《行政处罚决定书》。

【案件焦点】

行政处罚中没收违法所得应否扣除经营成本。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区东兴市人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款规定，当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。《中华人民共和国计量法》第二十六条规定，使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。

本案中，某海鲜摊于2023年4月30日购买了三台电子秤后进行调试，使得电子秤称量的产品重量显示为实际产品重量的1.2倍，并于2023年5月1日至2日使用上述三台电子秤销售海鲜完成474笔，营业额计90300.1元。某海鲜摊的行为属于以欺骗消费者为目的的故意违法行为，某市场监督管理局对某海鲜摊处罚没收违法所得90300.1元有事实和法律依据。关于某市场监督管理局、某市人民政府的法定职权、事实认定、行政程序的合法性审查问题，法院结合案件查明事实予以处理，各方当事人均无异议。

广西壮族自治区东兴市人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回某海鲜摊的诉讼请求。

某海鲜摊不服，提出上诉。广西壮族自治区防城港市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“没收违法所得”作为行政处罚的一个类型，其中“违法所得”的范围界定与计算标准问题，在学界与实务界争议较大，系本案中值得研究探讨的重点问题。

一、《中华人民共和国行政处罚法》修订前：“违法所得”多种标准并存

2021年《中华人民共和国行政处罚法》修订前，原《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条规定，行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或

8 中国法院2025年度案例·行政纠纷

者限期改正违法行为。可见，修订前的《中华人民共和国行政处罚法》对“违法所得”的范围和计算标准并未统一。但根据各部门处罚实践可知：“违法所得”的范围与计算主要存在“收入论”“收益论”和“折中论”三种观点。

“收入论”认为，当事人实施违法行为所取得的一切收入均属“违法所得”。例如，原国家安全监管总局《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十八条规定，违法所得包括销售收入、服务收入、报酬等。

“收益论”认为，“违法所得”系当事人实施违法行为所取得的收入扣除成本以后的收益。如原国家工商行政管理总局《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第二条“以当事人违法生产、销售商品或者提供服务所获得的全部收入扣除当事人直接用于经营活动的适当的合理支出，为违法所得”。

“折中论”认为，对当事人的“违法所得”，应视具体情况分析，综合考虑行为人的违法目的、主观意图、损害后果等。如行为人明知其行为违反行政法律法规，则应将违法行为持续期间取得的全部收入认定为“违法所得”；如行为人因过失实施违法行为，则仅应将其违法行为持续期间取得的利润认定为“违法所得”。

二、《中华人民共和国行政处罚法》修订后：以违法所得“全部收入”为原则

《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款规定，当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。此处明确了认定“违法所得”的基本原则与一般标准，即违法所得是指实施违法行为所取得的款项，不扣除成本，体现了“收入论”之观点。

此外，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款在确立“违法所得收入论”这一基本原则的同时，保留了“例外规定”，即“法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定”。考虑到行政执法领域的广泛性、差异性、复杂性，实务中在适用上述规定时应注意以下几点：

首先，应核查被处罚的违法行为属于哪一领域的法规规范，该领域法律、行政法规、部门规章是否有对“违法所得”作专门规定。

其次，若相关领域均无专门规定，则按以下方法处理：一是对于应退赔和已退赔的及已交税款从违法所得中扣除。二是对于违法情节不重、成本过大且清晰而收益不大者，出于比例原则和过罚相当原则考虑，可酌情考虑扣除合理成本。对违法所得可扣除合理成本者，必须采取限缩原则，框定于以下条件：(1)违法情节不重。重大的或故意实施的违法行为不适用。(2)成本清晰，可与违法所得相分离，如成本很难计算清楚，可不适用。(3)其他应考虑扣除成本的情形。实际上此处体现的是“违法所得折中论”。

本案中，某海鲜摊以欺骗消费者为目的，故意使用不合格的计量器具称重销售海鲜，仅两天营业额达90300.1元，本案在适用《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款时，查阅了计量器具领域的法规规范，在相关法规规范均未对“没收违法所得”如何计算作出细致规定的情况下，同时参考了国家相关部门对计量器具违法案件有关违法所得计算问题的回复所体现的精神。故，认定某市场监督管理局对某海鲜摊的营业额全部予以没收，符合“过罚相当”原则，未违反法律法规规定。

编写人：广西壮族自治区东兴市人民法院 冯建华 徐丽廷 周万林

对责任能力欠缺的行政相对人作出不予处罚决定 应通知其法定代理人或监护人陪同

——刘 某诉某派出所、某区政府不予行政处罚及行政复议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01行终944号行政判决书

10 中国法院2025年度案例·行政纠纷

2. 案由：不予行政处罚及行政复议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 刘某

被告(上诉人): 某派出所

被告: 某区政府

【基本案情】

刘某单独租住在位于某市某区公寓A室,其与租住在隔壁B室的邻居常某并不相识。刘某因认为存在噪音等问题,怀疑常某对其进行监控,遂在2021年2月21日20时34分许,刘某走到B室门口,测量B室门宽度及B室与A室的间隔宽度后回到A室。此时常某打开B室门,刘某随即从A室出来用脚触碰了B室门一下。双方发生短暂口角后各自返回屋内。间隔约1分钟后,刘某将一个瓶子放到B室门把手上,并在旁边观察了约2分钟后将瓶子取回,又用手机贴到B室门上播放警报声音。常某打开屋门,刘某用手机对常某进行了拍照。双方再次发生短暂口角后,刘某回到A室。常某随即拨打110电话报警,并到公寓楼外等待民警。在此期间,刘某持刀来到B室门口用手机贴到B室门上播放警报声音。常某听到警报声音后回到楼道内与刘某再次发生口角。在双方口角过程中,刘某实施了用刀拍打自己腿部、持刀放到身后和用刀柄指向常某的动作。常某随即又回到公寓楼外继续等待民警。刘某亦返回A室并关闭室门。

某派出所民警接警后立即出警,将刘某传唤至派出所,同时将常某及公寓管理员黄某一同带回派出所进行询问。

公寓管理员黄某在接受民警询问过程中,如实提供了刘某在公寓登记的紧急联系人信息情况,其中包括刘某的父亲电话、母亲的电话、姐妹的电话等情况。但民警在传唤刘某后,并未将有关传唤刘某的情况通知刘某的家属。

2021年2月22日,民警对本案制作了《受案登记表》,并向常某出具了《受案回执》。民警组织常某准确对刘某进行了辨认。

2021年3月14日,派出所经上级公安机关批准办理了《呈请延长办案时间审批表》,将本案的治安案件办案时间延长30日。

派出所于2021年3月18日向具有相关鉴定资质的某司法鉴定所出具《鉴定聘请书》，聘请对刘某在案发时的行为责任能力进行鉴定。该司法鉴定所根据派出所的委托，于2021年11月1日出具《司法鉴定意见书》：“……六、鉴定意见：被鉴定人刘某诊断为精神分裂症，案发时处于疾病期，其在实施违法行为时评定为无受治安处罚能力。”派出所于2021年11月4日将鉴定结果通过电话告知方式分别通知了刘某和常某。

派出所于2022年10月12日对刘某作出《不予行政处罚决定书》，主要内容为：现查明2021年2月21日20时许，违法行为人刘某在某区公寓楼道内，手持一把水果刀对邻居进行威胁，后被民警查获。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第十三条的规定，现决定不予行政处罚。同日，民警在派出所内向刘某同时送达《司法鉴定意见书》和《不予行政处罚决定书》。常某亦于当日领取《不予行政处罚决定书》。

2022年12月8日，刘某作为申请人以派出所作为被申请人，向当地的某区政府提交《行政复议申请书》及复议申请材料，复议请求：要求撤销《不予行政处罚决定书》。某区政府于当日受理后，于2022年12月9日向派出所送达《行政复议答复通知书》及《行政复议申请书》副本。派出所于2022年12月16日向某区政府提交《行政复议答复意见书》和证据材料及法律依据。某区政府在2023年2月3日以案情复杂为由，决定行政复议决定延期30日作出。某区政府采用书面方式审查后，于2023年3月4日作出《行政复议决定书》，认定派出所作出《不予行政处罚决定》书虽然认定事实清楚、证据确凿，适用法律依据正确，但存在未将传唤刘某的事项通知刘某家属、对于《司法鉴定意见书》超期送达刘某且未向常某依法送达、超过法定办案期限的问题，因此属于程序违法。依据《中华人民共和国行政复议法》规定，决定确认《不予行政处罚决定书》违法。某区政府后依法向刘某和派出所分别以邮寄方式进行了送达。

刘某仍不服，遂在法定期限内由其父亲作为法定代理人的情况下，向人民法院提起行政诉讼，诉讼请求：(1)撤销派出所作出的《不予行政处罚决定书》；(2)变更某区政府作出的《行政复议决定书》；(3)责令派出所对于引

发刘某在2021年2月21日被传唤的报警事项重新履行治安处理职责；(4)诉讼费用由派出所和某区政府承担。

【案件焦点】

在行政执法程序中，在行政行为相对人的责任能力欠缺的情况下，如何保障其合法权益。

【法院裁判要旨】

北京市石景山区人民法院经审理认为：派出所不仅在传唤刘某后，并未履行通知其家属的法定义务，而且在采信《司法鉴定意见书》的情况下，仍未通知刘某的父母或其他近亲属作为监护人或法定代理人参加治安处理行政程序。虽然《公安机关办理行政案件程序规定》对此没有明确规定，但结合本案的具体情况，派出所的前述行为不仅影响了刘某陈述申辩权的行使，而且实质影响了刘某的实体权利保障，因此应当属于违反正当程序原则。

派出所不仅未在法定期限内向刘某送达《司法鉴定意见书》，而且将《司法鉴定意见书》与《不予行政处罚决定书》同时向刘某进行送达的行为也违反了《公安机关办理行政案件程序规定》的相关规定内容，应属于违反法定程序。派出所在治安处理行政程序中作出《不予行政处罚决定书》的期限明显超过《中华人民共和国治安管理处罚法》前述规定，应属于违反法定程序。

派出所虽然在治安处理行政程序中接受了常某的报警，向常某进行了调查且组织了辨认，还向常某送达了《不予行政处罚决定书》，但在《不予行政处罚决定书》中，并未对刘某在本案中实施行为的受害人进行明确认定，因此仍应当属于认定事实不清。派出所在本案诉讼过程中无正当理由的情况下，并未向本院提供刘某实施行为时使用刀具的有关实物或照片或对该刀具采取保全措施等证据材料，应当属于提供证据并不充分。

由于派出所作出的《不予行政处罚决定书》存在前述执法程序、认定事实及提供证据等方面的违法情形，因此应当予以撤销。由于派出所对于引发刘某在2021年2月21日被传唤的报警事项，仍存在重新裁量处理的空间，因此应

当依法重新履行治安处理职责。

某区政府在采信《司法鉴定意见书》内容且未重新鉴定的情况下，并未通知刘某的父母或其他近亲属作为法定代理人参加行政复议程序，不利于实质保障刘某的合法权利，作出的《行政复议决定书》应当属于程序不当。

某区政府在被诉行政复议决定书中，虽然对于派出所传唤刘某后未通知其家属的行为、超期向刘某送达《司法鉴定意见书》的行为、办案超过法定期限的行为，均通过认定属于程序违法的方式进行纠正，但对派出所其他程序违法行为并未进行纠正；且亦未对《不予行政处罚决定书》未明确认定受害人的情况进行纠正；还未能提供证据证明在行政复议程序中对刘某实施行为时使用刀具的有关证据材料进行了充分审查。在此情况下，某区政府作出的《行政复议决定书》仅决定确认《不予行政处罚决定书》违法，而并未决定撤销，应当属于复议结果不当。

虽然某区政府作出的《行政复议决定书》存在前述不当情形，但并不属于人民法院判决变更行政行为的范围，故应当予以撤销。

综上所述，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第三项的规定，判决如下：

一、撤销派出所作出的《不予行政处罚决定书》；

二、撤销某区政府作出的《行政复议决定书》；

三、责令派出所在本判决书生效后的法定期限内，对于引发刘某在2021年2月21日被传唤的报警事项重新履行治安处理职责。

刘某和派出所均不服一审判决，并提出上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：一审法院以《不予行政处罚决定书》证据不足、程序违法为由予以撤销并责令派出所重新调查，同时一并撤销《行政复议决定书》的理由和结论正确，应予维持。派出所和刘某的上诉请求不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案审理中的主要争议焦点在于，公安机关对责任能力欠缺的精神病人进行调查和作出决定时，是否应当根据正当程序要求，通知其法定代理人或监护人到场。

当前，《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律规范中并没有对精神病人进行调查和决定工作作出特殊性程序规定。仅对一般违法行为人及未成年人的调查和决定程序进行了规定。例如，《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十三条规定：“对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证……公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。”第八十四条规定：“……询问不满十六周岁的违反治安管理行为人，应当通知其父母或者其他监护人到场。”

本案中，派出所虽然对刘某作出的是《不予行政处罚决定书》，但在该决定书中却是确认了刘某实施了违法行为，仅是以刘某不具备承担治安处罚责任能力为由，才决定不予处罚，而不是确认刘某没有任何违法行为或违法事实不成立，决定不予处罚。因此该《不予行政处罚决定书》对于刘某而言，并不属于纯获利益的行政决定，而是属于会导致对刘某产生法律上不利评价与影响的行政决定。因而，本案不能根据“纯获利益行为无需代理人同意或追认”规则，佐证对刘某的不予处罚决定可以不通知其代理人。^①

在这种情况下，由于刘某在本案中不具有独立参加治安行政活动的行为能力，从更有利于保障刘某的合法权益的角度出发，派出所不通知刘某的法定代理人或监护人或其他近亲属或亲属到场，不仅没有充分履行《中华人民共和国治安管理处罚法》《公安机关办理行政案件程序规定》中规定的法定调查处理职责，也未能真正查清相关案件事实情况，而且没有确保刘某在治安行政程序中真正行使《中华人民共和国治安管理处罚法》《公安机关办理行政案件程序

^①《中华人民共和国民法典》第一百四十五条第一款规定：“限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。”

规定》中规定的相关陈述权、申辩权、发表意见的权利。这样实际上会致使前述法律规定的所有调查、处理程序性规定均无法实现法律价值，刘某的合法权益也无法在治安执法活动中得到有效保障。

因此，派出所在传唤刘某之后，及时通知刘某的法定代理人或监护人或其他近亲属或亲属参加治安行政活动的法律意义，就不仅仅只是《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十三条规定的在传唤刘某之后应及时通知家属的法定程序意义，而应当理解为在刘某不具有独立参加治安行政活动行为能力的情况下，真正查明事实，真正确保听取刘某的意见，保障刘某对于治安行政执法活动的实质参与权及相关合法权益不被侵害，而不使派出所的调查工作流于形式的正当程序意义。

综上所述，为确保派出所真正查明案件事实，真正保障刘某的合法权益，虽然法律没有明确规定公安机关对精神病人进行调查和作出决定时必须通知其法定代理人或监护人，但派出所也应根据正当程序要求，必须通知刘某的法定代理人或监护人到场。而且根据本案中的具体情况，派出所在调查过程中，通过公寓管理员黄某实际掌握了刘某父母和姐妹的联系方式，因此实际上派出所也具备通知刘某的法定代理人或监护人参加治安行政执法活动的条件。在此情况下，人民法院确认派出所在治安行政执法活动中，在采信《司法鉴定意见书》的情况下，仍未通知刘某的父母或其他近亲属作为监护人或法定代理人参加治安处理行政程序的行为，属于违反正当程序，是正确的。同样道理，人民法院确认某区政府在采信《司法鉴定意见书》内容且未重新鉴定的情况下，并未通知刘某的父母或其他近亲属作为法定代理人参加行政复议程序，不利于实质保障刘某的合法权利，作出的《行政复议决定书》亦应属于程序不当，也是正确的。

编写人：北京市石景山区人民法院 滕恩荣

瞒报生产安全事故属于具有继续状态的违法行为

—— 某公司诉某区应急管理局行政处罚案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省临沂市中级人民法院(2023)鲁13行终80号行政判决书

2. 案由：行政处罚纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某公司

被告(被上诉人): 某区应急管理局

【基本案情】

2022年1月22日,某省政府安委会办公室向各市政府安委会下发《关于抓紧做好审计发现部分市县涉嫌瞒报漏报事故核查和整改工作的通知》。某公司涉嫌瞒报2018年11月20日发生的生产安全事故。2022年3月20日,某区安全生产委员会办公室出具某公司某项目一般高处坠落生产安全事故调查报告。

1. 事故发生经过:2018年11月20日7点58分左右,某公司职工李某在某项目部办公室简单交流工程进度后,于8点11分自行到项目工地7号楼进行工作检查。14点40分左右,广西某公司工人史某寻找施工过程中落下的梯子时发现有人趴在7号楼负三层电梯井,立即上报项目分管经理并报警。17点40分左右将电梯井内人员搬运到地面,经辨认系该单位职工李某(120医护人员确认已死亡)。经公安部门调查,李某死亡原因无法查明是失血性休克死亡还是溺亡。

2. 善后处理情况：某公司和死者亲属达成赔偿协议，并申报工伤认定、死亡赔偿等各项赔偿共计170万元已经全部赔偿到位。

3. 事故发生原因及性质。(1)直接原因：李某在检查工程进度时不慎坠落电梯井基坑内死亡。(2)间接原因：安全设施及警示标志缺失。事故发生时，7号楼负二层南侧电梯井周围用四条钢筋搭建的简易护栏，不符合国家标准要求；没有设置“当心坠落”“禁止靠近”等安全警示标志；(3)事故性质：经调查认定，某公司职工李某坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。事故发生后，某公司及负责人未向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，属于瞒报。

某区人民政府批复同意事故调查组对事故的原因分析和责任认定，以及对有关责任人和责任单位的处理建议。某区应急管理局对某公司瞒报一般生产安全事故一案立案调查并作出处罚。

【案件焦点】

某公司瞒报生产安全事故的行为，是否应当适用《中华人民共和国行政处罚法》“违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚”的规定。

【法院裁判要旨】

山东省临沂市兰山区人民法院经审理认为：向有关主管部门报告生产事故，是生产单位应尽的义务，不论事故发生多长时间，生产单位都有义务向主管部门报告曾经发生生产事故的情况，瞒报属于持续性的违法行为，故某公司主张超过处罚时效的理由不能成立。某区应急管理局作出的案涉行政处罚决定认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，程序合法，处罚适当。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回某公司的诉讼请求。

某公司不服一审判决，提出上诉。

山东省临沂市中级人民法院经审理认为：瞒报生产安全事故属于具有继续状态的违法行为。因此不论事故发生多长时间，生产单位都有义务向主管部门

报告曾经发生的生产安全事故的情况。山东省临沂市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十六条、第八十九条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

有的生产经营单位及其有关负责人在生产安全事故发生后，抱有侥幸心理，幻想着“大事化小、小事化了”，瞒报生产安全事故，导致贻误救援，使小事故升级成重大事故，造成无法挽回的重大损失。

对瞒报生产安全事故超过二年的应如何处理，在执法、司法实践中有不同认识。有观点认为，瞒报不属于持续性的违法行为，超过两年未被发现的，应当不再给予行政处罚。另一种观点认为，瞒报属于持续性的违法行为，较迟报行为更为恶劣，需要依法从严查处。但在司法实践中，对于瞒报为什么属于持续性的违法行为没有分析阐释，缺乏有力的论证基础。

本案中，从某省人民政府安委会办公室下发的《关于抓紧做好审计发现部分市县涉嫌瞒报漏报事故核查和整改工作的通知》来看，生产经营单位瞒报、漏报生产安全事故的行为数量多、涉及面广，社会影响大。极有必要对该问题进行明确回答，从而统一认识和裁判尺度。

本案从法律责任本质、瞒报行为性质、瞒报和迟报行为相互关系以及社会价值导向等方面，详细论证了瞒报生产安全事故行为应属具有继续状态的违法行为，应从行为终了之日起计算追责期限，而不能适用违法行为在二年内未被发现的不再给予行政处罚的规定。

将瞒报生产安全事故界定为具有继续状态的违法行为，符合违法行为必然产生法律责任的法学理论。法体现了社会的价值观念，是指引和评价人的行为的规范。法律责任的本质是对行为的规范评价，对违反法律规范的行为持否定性态度。《中华人民共和国安全生产法》规定了生产经营单位及其主要负责人及时、如实报告生产安全事故的职责。如果生产经营单位及其主要负责人没有履行及时、如实报告生产安全事故的职责，那么，在没有法律规定减轻或者免

除法律责任的情形下，生产经营单位及其主要负责人就要承担法律责任，从而弥补社会损害，恢复被损害的社会秩序，维护社会公正。

将瞒报生产安全事故界定为具有继续状态的违法行为，能够切实有效发挥及时、如实报告安全事故的制度价值。生产安全事故具有复杂性、不确定性和处置紧迫性等特征，如果对事故信息掌握不准确，很容易错过最佳处置时机，进而导致事故后果扩大，也不利于后期的事故调查顺利开展。法律规定及时、如实报告安全事故的作用就是迅速、全面掌握事故信息，从而有效应对突发事件，把握最佳救援时机，最大程度拯救生命和减少财产损失。而瞒报生产安全事故会贻误救援，扩大事故造成的损失，是对安全生产法治环境的严重破坏，是严重的违法行为，必须予以严肃处理。

将瞒报生产安全事故界定为具有继续状态的违法行为，符合文义解释和体系解释的要求。《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第一项规定：“报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。”由此可见，首先，根据该规定的文义内容，超过规定时限报告事故，无论超过多长时间，都属于迟报行为。那么，对于迟报行为的处罚，自然不受行政处罚法规定的两年的追责期限的限制。而瞒报行为，其行为性质较迟报行为更为恶劣，理应承担更为严重的法律责任。其次，法律法规对迟报生产安全事故的行为予以处罚，即说明及时、如实报告生产安全事故的义务并不仅仅限于法律法规规定的报告期限之内。如果认为及时、如实报告生产安全事故的义务仅限于法律法规规定的报告期限之内，那么追究迟报、瞒报违法者就没有依据可循。

将瞒报生产安全事故界定为具有继续状态的违法行为，符合法律、政策的价值取向，体现社会主义核心价值观的根本要求。《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，确立了严格安全生产责任追究制度，要求从严查处瞒报、谎报、漏报、迟报事故行为。将瞒报生产安全事故界定为具有继续状态的违法行为，从而应当从违法行为终了之日其计算追责期限，体现了上述法律法规从严查处瞒报事故行为的精神，也是诚信、公正、法治等社会

主义核心价值观的体现。

综上，瞒报生产安全事故属于具有继续状态的违法行为，应依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条第二款“违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日其计算”的规定计算追责期限，从而充分发挥事故报告制度的效用，警示督促有关生产经营单位 and 责任人员放弃侥幸心理，及时如实报告生产安全事故，有效处置突发事件，最大程度减少损失，维护人民群众生命财产安全。

编写人：山东省临沂市中级人民法院 邵锐

5

美容公司“超范围经营”与其工作人员“无证开展医疗美容服务”同时受到行政处罚不违反“一事不二罚”原则

——岳某诉某县卫生健康局行政处罚案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2024)鲁03行终4号行政判决书

2. 案由：行政处罚纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):岳某

被告(被上诉人):某县卫生健康局(以下简称某卫健局)

【基本案情】

2022年11月1日，被告某卫健局在检查中发现原告岳某涉嫌未注册取得医师执业证书在某医疗美容诊所开展医疗美容服务。2022年12月28日，被告

某卫健局作出18号行政处罚决定书，认定原告的行为违反了《中华人民共和国医师法》第十三条第四款的规定，依据《中华人民共和国医师法》第五十九条规定，决定给予岳某罚款人民币贰万元整(¥20000.00)的行政处罚。同日，某卫健局以某医疗美容诊所超范围开展医疗美容诊疗活动以及使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作，违反《医疗机构管理条例》第二十六条、第二十七条的规定，作出17号行政处罚决定书。原告认为，被告已认定原告系某医疗美容诊所工作人员，且对某医疗美容诊所作出17号处罚后，再引用《中华人民共和国医师法》第五十九条对原告个人进行处罚，违反了“一事不二罚”原则，因此提起行政诉讼，要求撤销被告作出的18号行政处罚决定书。

【案件焦点】

美容公司“超范围经营”与其工作人员“无证开展医疗美容服务”同时受到行政处罚是否违反“一事不二罚”原则。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市桓台县人民法院经审理认为：《医疗美容服务管理办法》第十一条规定，负责实施医疗美容项目的主诊医师必须同时具备下列条件：（1）具有执业医师资格，经执业医师注册机关注册；（2）具有从事相关临床学科工作经历。其中……负责实施美容中医科和美容皮肤科项目的应分别具有3年以上从事中医专业和皮肤病专业临床工作经历；（3）经过医疗美容专业培训或进修并合格，或已从事医疗美容临床工作1年以上；（4）省级人民政府卫生行政部门规定的其他条件。第十二条规定，不具备本办法第十一条规定的主诊医师条件的执业医师，可在主诊医师的指导下从事医疗美容临床技术服务工作。第十四条规定，未经卫生行政部门核定并办理执业注册手续的人员不得从事医疗美容诊疗服务。由上可知，实施医疗美容项目的主诊医师应当首先取得执业医师资格，本案原告岳某并未取得执业医师资格。结合原告所使用的仪器说明书及《医疗美容项目分级管理目录》内容，可确定，强脉冲光（IPL）治疗属于医疗美容中美容皮肤科项目。故，被告某县卫生健康局在收集现场笔录、询问笔录、

取证照片及相关记录等证据的基础上，认为原告岳某未取得《医师资格证书》《医师执业证书》擅自在某医疗美容诊所开展医疗美容服务，并依据《中华人民共和国医师法》第五十九条的规定，对原告岳某作出《行政处罚决定书》，认定事实清楚，证据充分，适用法律正确。且，被告某县卫生健康局依法履行了立案、调查、告知、决定、送达等程序，处罚决定程序合法。判决如下：

驳回原告岳某的诉讼请求。

岳某不服一审判决，提出上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：根据《医疗美容项目分级管理目录》规定，强脉冲光（IPL）治疗属于医疗美容中美容皮肤科项下治疗项目。根据《医疗美容服务管理办法》规定，负责实施医疗美容项目的主诊医师必须具有执业医师资格，经执业医师注册机关注册。不具备主诊医师条件的执业医师，可在主诊医师的指导下从事医疗美容临床技术服务工作。未经卫生行政部门核定并办理执业注册手续的人员不得从事医疗美容诊疗服务。因此，被上诉人某卫健局认定上诉人岳某未取得《医师资格证书》《医师执业证书》，使用强脉冲光脱毛/嫩肤仪为顾客进行面部美容，具有事实根据和法律依据。上诉人岳某还主张其系某医疗美容诊所工作人员，其行为属于职务行为，处罚的对象应为某医疗美容诊所，在已对公司进行处罚的情况下，不应再对工作人员个人进行处罚。对此，法院认为，医疗行业作为关乎公众生命健康的特殊行业，法律、法规等对相关从业机构和人员均制定了严格要求。不仅医疗机构的设置、执业、使用人员等有相关规定，对具体从事医疗行业的人员所需要的相关资格、资质等亦有专门规定。本案中，被上诉人某卫健局对某医疗美容诊所进行处罚系因其超范围开展医疗美容诊疗活动以及使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作，违反了《医疗机构管理条例》第二十六条、第二十七条的规定，进而依据《医疗机构管理条例》第四十六条、第四十七条的规定予以处罚。而对上诉人岳某进行处罚则系因其未取得《医师资格证书》《医师执业证书》的情况下开展医疗美容服务，违反了《中华人民共和国医师法》第十三条第四款的规定，进而依据《中华人民共和国医师法》第五十九条进行处罚。被上诉人某卫健局

分别针对医疗机构和从事医疗行业的人员不同主体违反不同法律、法规的行为予以处罚，并无不当。上诉人岳某关于在对某医疗美容诊所处罚后不应再处罚工作人员的主张缺乏依据，不能成立，本院依法不予支持，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

要正确处理好本案，关键在于如何理解《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚”的规定，才能正确判断原告的违法行为与单位的违法行为是否属于“一事”，进而判断能否“二罚”？

在我国，行政处罚属于行政制裁范畴，是国家对违反行政管理法规的组织以及个人依法进行教育、惩戒的行为，其最终目的是让行为人或组织不会产生同一违法行为的重犯。行政处罚“一事不二罚”原则中的“一事”，指当事人的“同一个违法行为”。如何认定“一事”，就是如何认定“同一个违法行为”。这一违法行为是一个独立存在的违法行为，并不是一类违法行为。因此，对于同一个违法行为的准确界定，是“一事不二罚”原则实施的前提和基础。

一、“一事”的界定

将行为的同质性及构成要件中各行为所保护法益是否相同作为认定标准，同时满足行为同质性与保护法益相同，则视为“一事”。例如，《中华人民共和国产品质量法》第三十九条规定，销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。从该条的规定来看，诸多情形所涉行为是同质的，即以瑕疵产品冒充无瑕疵产品，其目的均是保护消费者的合法权益，因此违反上述情形，无论是出现一种还是多种行为，都可视为行为单数即“一事”。在此认定上，如果还触犯其他法律规范，则属想象竞合，择一重处。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，

可以并处一千元以下罚款。由于该条规定中不同行为的异质性，且保护的权益也各有侧重，则应当视为行为复数，分别处罚。因此，同一违法事实的“一事”应当是侵害的法益同一，具备独立性、完整性、客观性的单独存在。

一是具备行政法律规范所保护并已经被违法行为所侵害的法益。法律的一个重要目的是为了保护法益，因此，在进行行为评价时，法益这个因素应当被充分考虑。从大的方面来讲，法益即违法客体，在行政法领域可以称之为行政管理秩序。具体而言，根据法益的主体可分为国家法益、社会法益和个人法益。个人法益主要包括财产法益和人身法益。人身法益主要包括生命、健康、名誉等法益，由于其具有个人专属性，应当分别评价，此时即便是出于单一或概括的故意针对不同对象而进行的行为，亦不应评价为一个行为。而关于财产类的法益侵害的是一行为还是多行为则不能一概而论。如盗窃物品后又毁坏的行为，由于实质上仅侵害一个财产所有权，被侵害的财产法益具有重合性，一般应以一行为论处。关于财产法益，如果一个行为侵害了数个法益，是否成立数行为还须结合其他因素综合权衡，看是否存在例外情形，如不存在，则应当认定为一行为。而侵犯国家、社会法益的情形则比较复杂。法益之间往往具有包容性，即一种法益被包容于另一种法益之中。如擅自转让行为侵害了海关对监管货物的所有权从而侵害了国家税收等法益，而擅自发运行为则侵害了海关对所监管货物的占有，但擅自转让行为一般都包含了擅自发运行为，擅自转让必然有擅自发运，此时由于擅自发运可包容于擅自转让的行为之中，如一行为为擅自转让，则进行评价时无须再评价其中的擅自发运行为，因此仅以擅自转让一个行为进行评价。具体到案件中，《中华人民共和国医师法》第十三条规定：“国家实行医师执业注册制度……未注册取得医师执业证书，不得从事医师执业活动。”该规定保护的法益是个人法益中的人身法益。原告未取得《医师资格证书》《医师执业证书》而在某医疗美容诊所开展医疗美容服务，侵犯的是被服务人员的人身法益，即身体健康的合法权益。《医疗机构管理条例》第二十六条规定，医疗机构必须按照核准登记或者备案的诊疗科目开展诊疗活动。第二十七条规定，医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。该规

定规范的是医疗机构的经营秩序。根据上述规定，某医疗美容诊所存在超范围经营以及使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术的行为，侵犯的是社会法益。因此，原告侵犯的法益不能被某医疗美容诊所侵犯的法益所包容。且二者的违法行为均已侵害了法律所保护的法益。

二是违法行为所侵害的法益是否具备同一性。内容同质为法益同一性提供了可能。当然，内容同质并不等于法益同一。这是因为法益内容是否同质，只是对法律条文规范目的的抽象判断；而法益同一性判断，则是对行为事实所侵害的法益具体内容是否能为一个行政处罚规定所包含的具体判断。案件中，《医疗机构管理条例》第二十六条规定，医疗机构必须按照核准登记或者备案的诊疗科目开展诊疗活动。因此，医疗机构应该在核准登记或者备案的诊疗科目范围内开展医疗活动。但某医疗美容诊所作为医疗美容公司则存在“超范围经营医疗活动”，其侵害的是医疗卫生机构诊疗从业市场的经营秩序与公共卫生管理秩序，违背了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第一条关于“发展医疗卫生与健康事业，保障公民享有基本医疗卫生服务，提高公民健康水平，推进健康中国建设”的立法目的。该法保护的法益是医疗卫生机构与医疗卫生人员的执业行为。而原告在未取得医师资格证书、医师执业证书的情况下擅自从事医疗美容执业活动，即“无证行医”，违背了《中华人民共和国医师法》第一条关于“保障医师合法权益，规范医师执业行为，加强医师队伍建设，保护人民健康，推进健康中国建设”的立法目的。该法侧重于评价医师的执业行为。侵害的法益是国家对于医师执业的管理秩序以及就诊者的生命健康安全。因此，某医疗美容诊所的违法行为与原告违法行为侵害的法益在内容上不具有同一性。

三是多个具体法律行为之间的关系是否存在关联性。这里的关系既包括先后顺序，也包括因果关系。当多个具体法律行为存在先后次序，如必经阶段、组成部分、当然结果，可以认定为同一违法行为。倘若多个具体法律行为之间具有目的与手段、原因与结果等因果关系，此时也可以认定为同一违法行为。具体到案件中，某医疗美容诊所的违法行为是因为其超范围经营以及使用非卫

生技术人员从事医疗卫生技术工作，违反的是《医疗机构管理条例》第二十六条、第二十七条的规定。原告的违法行为是因为未取得《医师资格证书》《医师执业证书》擅自在某医疗美容诊所开展医疗美容服务的行为，违反的是《中华人民共和国医师法》第十三条第四款的规定。两个违法行为无论是在违法行为的性质上还是在所触犯的法律规定方面均不相同，因此，某医疗美容诊所的违法行为与原告的违法行为是两个独立的违法行为，两个行为之间不存在先后顺序，亦不存在因果关系等，因此，不具有任何关联性。

四是实施主体是否为同一个违法行为人。一般情况下，同一违法行为的实施主体是同一个违法行为人。例外情况下，在共同实施违法行为时，虽然违法行为人不同，但基于共同的违法事实，也应认定为“同一违法事实”，对共同违法行为人分别实施处罚，也不违反“一事不二罚”原则。而案件中，首先，某医疗美容诊所与原告是两个不同的违法主体，一个是法人、一个是自然人。其次，二者在违法的事实、性质、违反的法律规定等方面均不相同。二者亦不存在共同的违法动机和违法故意，因此，不属于共同违法。故，某医疗美容诊所与原告在违法主体方面不能视为同一个违法行为人。

综上，某医疗美容诊所与原告的违法行为不属于“一事”即同一违法行为，因此亦不存在违反“二罚”的规定，可以依据各自违法行为违反的法律规定分别作出处罚。

二、行政处罚案件“一事不二罚”原则的检验

“一事不二罚”是我国行政法理论和实际执法中普遍适用的一个原则，但其具体含义和判定标准却存在争论。对一事不二罚原则的适用，可以选择多种学说中的某一种，但无论选取哪一种学说来适用一事不二罚原则，均可以从以下三个方面来进行检验：

第一，是否符合立法目的。我国行政处罚法第六条规定，实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。由于行政处罚对相对人的权利义务影响甚重，因此，对其适用不得不十分谨慎。行政处罚法也并非以处罚作为立法目的，而是为了引导教育违法行

为人进行改正，这是行政处罚法的一个大方向。案件中，对某医疗美容诊所与原告的处罚分别是基于不同的法律规定，规范不同的社会秩序，并未违反行政处罚的目的，符合行政处罚法教育与处罚的立法目的。

第二，是否违反比例原则。无论是对当事人的违法行为进行一次行政处罚还是多次处罚，核心都不能突破比例原则，即过罚应具有相当性。行政机关遵循一事不二罚原则对当事人的一个违法行为只进行一次处罚，也应当把握好处罚的度，不能因为一事不能二罚，而在法律规定的幅度内不加限制地对当事人进行处罚，而是应当在适合当事人违法程度的幅度内进行处罚才是合法、合理的。从行政主体的角度来看，行政处罚的目的在于制裁违法行为，维护公共利益和社会秩序，教育公众自觉守法，因此，行政处罚的力度应与当事人的过错程度、社会危害程度相适应、成比例，既不能处罚过重或重复处罚，也不能处罚过轻，使违法者逃脱责任。因某医疗美容诊所与原告的行为分别违反的是《医疗机构管理条例》和《中华人民共和国医师法》两个法律规定，对其分别予以处罚，且对二者的处罚亦在法定幅度内，因此未违反比例原则，能够更好地处罚违法者，恢复受损的社会秩序。

第三，当事人是否具有期待可能性。比如，当事人在接到行政机关的告知后，这时当事人是需要一定的合理期间来进行改正的，而不能由于当事人没能立即改正违法行为就让当事人再次接受处罚，因为在绝大多数场合下，当事人立即改正违法行为不具有期待可能性。本案中涉及两个不同的违法主体某医疗美容诊所与原告，因此，一个案件的违法行为人对另一个案件的违法行为是不具有违法阻却事由的期待可能性。分别对其进行处罚，不违反期待可能性的原则。

编写人：山东省淄博市博山区人民法院 郑娟

山东省淄博市中级人民法院 刘敏

食药同源产品的性质应当结合其主要成分、 制作方法、宣传用途等进行综合判定

——郑某诉街道办、市政府行政处罚及行政复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02行终323号行政判决书

2. 案由：行政处罚及行政复议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):郑某

被告(被上诉人):街道办、市政府

【基本案情】

2019年3月起,郑某租赁小作坊一间用于生产“瘦身消脂茶”(以下简称消脂茶)等产品。消脂茶的主要成分有:山楂、荷叶、薏仁、芡实、白术、茯苓、泽泻、莲子、桂枝、干姜、大枣、陈皮等,外包装上写有“男女通用、反对节食、健脾消脂、促进代谢、开水冲服、忌食寒凉”等内容。2021年7月起,郑某通过其注册的微店销售消脂茶,价格分别为192元/包、216元/包、240元/包,至2022年3月累计销售1182包,金额共计243408元。

2022年3月5日,市监局执法人员在检查中发现郑某涉嫌未取得《食品生产许可证》或《小作坊登记证》生产消脂茶,在市监局调查过程中,郑某称消脂茶的主要工序是打粉、灌装,在其诊所抓药混合,用塑料袋装好用粉碎机打粉,灌到茶包里封口,再装入纸袋中就完成了,消脂茶主要功效为健脾、化湿、

利尿、扶阳、消脂，其中肯定没有西药成分，都是用的中药饮片。因行政处罚权相对集中调整，市监局将该线索及相关证据材料移交街道办立案调查。在街道办调查过程中，郑某称消脂茶配方是固定的，所有人通用，主要销售人群是自我感觉肠胃不好、肥胖、大便溏稀的，其认为消脂茶是一款代茶饮，没有申请食品生产许可。

2022年9月5日，街道办认定郑某生产售卖消脂茶的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十五条的规定，遂对郑某作出没收违法生产经营的食品和生产工具、没收违法所得，并处罚款的行政处罚决定。郑某不服该处罚决定，向市政府提起行政复议，2023年1月16日，市政府作出维持原处罚决定的复议决定书。郑某又以行政机关对消脂茶定性为食品没有依据等理由起诉至法院，请求撤销案涉处罚决定书及复议决定书。

【案件焦点】

案涉消脂茶应当被认定为食品还是药品。

【法院裁判要旨】

江苏省江阴市人民法院经审理认为：《中华人民共和国食品安全法》第一百五十一条第一款规定：“食品，指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。”《中华人民共和国药品管理法》第二条第二款规定：“本法所称药品，是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药、化学药和生物制品等”。

本案中，根据《卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知》，消脂茶主要成分中的山楂、荷叶、薏仁等属于《既是食品又是药品的物品名单》，白术、泽泻属于《可用于保健食品的物品名单》，经检测，消脂茶中不含有被禁用的西布曲明成分，故消脂茶原料选材均为食药同源物品，其性质应根据制作工艺、宣传功能等因素加以界定。首先，消脂茶外包装显示其主要用途是健脾消脂、促进代谢等，未规定具体的适用证或功能主治，未限定具体适用人群，

未规定医学上的用法用量，未强调其药物属性。其次，消脂茶主要的工序就是原料混合、打粉、灌装，与中医药所强调的加工炮制等特定工序不同。最后，郑某在调查中自身也认为消脂茶系一款“代茶饮”，进一步证明其并不以治疗为目的。综上，街道办将消脂茶定性为食品并无不当。

江苏省江阴市人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、七十九条之规定，判决如下：

驳回郑某的全部诉讼请求。

郑某不服一审判决，提出上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系人民法院依法支持行政机关强化统一市场监管执法的典型案例。近年来，许多商家抓住了减肥者“身材焦虑”心理，通过宣传产品“减肥”功效来吸引消费者购买，而大部分减肥产品原料选材均为“食药同源”物质。“食药同源”物质在属于食品还是药品上没有明确界限，既能当作食物食用，同时又具有治疗功效。由于《中华人民共和国食品安全法》对食品的经营管理以及《中华人民共和国药品管理法》对药品的经营管理各自有明确的规定，因此，市场监管部门对此类产品进行查处时，将产品性质认定为食品还是药品对最终的处罚决定具有重大影响。法院在审查此类案件时，也需首先对产品性质作出认定，方可进一步审查行政处罚之合法性。

选材为“食药同源”物质的产品性质具体如何认定，应当从主要成分、制作工序、宣传功能等方面进行综合考量。首先，需明确产品是否含有西布曲明等西药成分。其次，从制作工序看，中医药品往往具备炮制等特定工序，如果仅仅是通过原料混合、打粉、装罐等程序制作而成，则更偏向于食品范畴。最后，从宣传功效看，药品往往会规定具体的适用证或功能主治以及医学上的用法用量，若产品标签其他表述中无适用病症、主治病症或预防病症等药品特征表述，不以治疗为目的，则不宜将其认定为药品范畴。本案中，消脂茶用食药

同源物品粉碎后以袋装沸水泡服，并主要宣称有减肥功能，原料及宣传并未强调其药品属性，故与《食品生产许可分类目录》里保健食品中的茶剂种类相符，定性为食品并无不当。另外，既然案涉消脂茶作为一款“代茶饮”属于食品而非药品，且国家对食品生产经营实行许可制度，同时规定食品生产加工小作坊和从事食品生产经营活动需要办理许可证，那么消脂茶的生产应当符合《中华人民共和国食品安全法》规定的生产经营规模、条件相适应的食品安全要求，保证所生产经营的食品卫生、无毒、无害。

本案对消脂茶属于食品还是药品进行了充分的论证并明确了认定标准，在认定消脂茶属于食品的基础上全面查清事实、准确适用法律，最终判决支持行政机关对案涉违法行为予以严格处罚，一方面充分表明人民法院对食品安全领域违法犯罪“零容忍”的态度和立场，对增强各类市场主体法治意识、预防违法行为具有重要警示教育作用；另一方面有力保障行政机关整顿市场，对食品安全领域违法行为下重拳，改善消费环境，强化消费者权益保护，支持提升消费服务质量。

编写人：江苏省江阴市人民法院 孙妍 沈金锋 顾彧

未明示收集目的、未经同意使用消费者个人信息的行为违法

— 某公司诉某市市场监督管理局责令改正及罚款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通经济技术开发区人民法院（2023）苏0691行初81号行政判决书

2. 案由：责令改正及罚款纠纷

3. 当事人

原告：某公司

被告：某市市场监督管理局(以下简称某市监局)

【基本案情】

某公司注册成立于2008年8月13日，经营范围为建筑装修装饰工程专业承包(凭资质证书承接业务)、装潢材料销售。某公司未明示收集、使用信息的目的、方式和范围及未经被收集信息者同意，通过客户上门咨询登记、小区驻点采单等方式登记某小区业主个人信息1057条。

2022年4月14日，某市监局到某公司经营场所进行执法检查时，发现办公桌上摆放前述消费者个人信息明细单，内容包括姓名、联系方式、楼室号等，并备注“未接”“挂了”“暂时不装”“不装修”“拒接”“空号”“不考虑”“装好了”等状态。当日，某市监局制作现场检查笔录、对消费者个人信息明细表拍照留存，某公司法定代表人现场陪同检查，并在现场检查笔录上签字确认。

因某公司收集、使用消费者个人信息的行为涉嫌违法，某市监局于4月25日立案调查。同日，某公司法定代表人丁某、业务员范某至某市监局处接受调查，并认可实施了收集1057条消费者个人信息的行为，对收集信息时未告知消费者使用目的、出于商业营销目的对信息进行使用的行为亦无异议，因行情不好一直没有成交。为调查某公司获利情况，某市监局于同日向某公司作出《限期提供材料通知书》，要求某公司提供近三年财务账册及损益表。后某公司向某市监局提供了2019年至2022年4月的资产负债表及利润表，显示某公司并无利润。

7月11日，某市监局作出行政处罚决定，认定某公司通过客户上门咨询主动登记，小区驻点采单等方式向消费者收集了1057条消费者个人信息，但是在收集的时候没有向消费者明示收集信息的目的。某公司工作人员对前述消费者进行电话营销，出于商业目的使用该1057条消费者个人信息。某公司的行为违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条第一款的规定，根据该法第五十六条第一款第九项的规定，责令某公司立即改正违法行为，并处罚款30000元。

【案件焦点】

1. 认定事实是否清楚。即某公司是否存在收集信息时未明示收集目的，未经消费者同意使用1057条个人信息的行为；某公司是否有违法所得。2. 适用法律是否正确。3. 处罚程序是否合法。4. 量罚是否适当。

【法院裁判要旨】

江苏省南通经济技术开发区人民法院经审理认为：首先，无论是《中华人民共和国民法典》还是《中华人民共和国个人信息保护法》，均明确了保护个人信息权益以及促进个人信息合理利用的基本原则并规定侵害个人信息权益应依法承担法律责任。具体到本案，所涉1057条信息内容涵盖了两个小区部分业主的姓名、联系方式、楼室号等，这些信息相结合显然可以定位到特定个人，具有明显的个人可识别性，属于前述法律规定的应受法律保护的个人信息的。其次，某公司在收集信息时未明示收集目的，未经消费者同意使用1057条个人信息，有相应陈述及询问笔录为证，违法收集、使用消费者个人信息的行为事实清楚。关于某公司提出其收集信息时经过消费者同意，故不属于违法行为的意见。某公司属于混淆了使用行为与使用结果之间的关系。某公司以拨打电话、添加微信等方式招揽业务事实上就是使用案涉登记的个人信息行为，至于消费者是否接听电话、是否同意装修等均属于使用信息后产生的结果，两者是不同性质的概念，不可混同。最后，处罚决定认定某公司无违法所得并无不当。所谓违法所得，是指因违法行为获得的作为收入的款项。某公司提供的资产负债表及利润表显示，某公司并无获利，该事实与某公司法定代表人、业务员的陈述相互印证，故认定某公司无违法所得，具有事实根据。此外，处罚决定适用法律、程序、量罚均合法适当。

综上，江苏省南通经济技术开发区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回某公司的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

随着数字化时代的到来，个人信息保护已成为一个日益重要的问题。个人信息不仅关系到个人的隐私权，也涉及数据安全和个人权益的保护。《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条对经营者收集、使用消费者个人信息时应当遵循的原则、履行的义务作了规定，并在第五十六条规定了侵害消费者个人信息的法律后果。民法典颁布后，为了规范个人信息的处理活动，保护个人信息主体的合法权益，促进信息资源的合理利用，维护网络空间的公共利益和社会秩序，我国制定了个人信息保护法。个人信息保护法作为消费者权益保护法、网络安全法等法律规范的“一般法”地位，与消费者权益保护法、网络安全法共同组成了对个人信息的全方位保护。

一、个人信息的含义及保护意义

《中华人民共和国民法典》第一千零三十四条第二款以及《中华人民共和国个人信息保护法》第四条第一款对个人信息作出了定义，即以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等，不包括匿名化处理后的信息。个人信息的核心特点为可识别性，包括对个体身份以及个体特征的识别，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式、家庭住址、健康信息等，这些都是个人隐私的一部分。保护个人信息，就是保护个人隐私不被侵犯。个人信息的泄露可能导致身份盗用，给个人带来经济损失和信用损害，个人信息的滥用也可能会被用于诈骗、骚扰等违法行为，扰乱社会秩序。

二、消费者权益保护法第二十九条第一款的理解与适用

《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条第一款规定，经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。该条在实践中需要正确适用，主要涉及处理个人信息应当遵

循的原则、收集使用信息的合法要件等内容。

1. 处理个人信息应当遵循的原则

根据《中华人民共和国民法典》第一千零三十五条规定，处理个人信息必须遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。为保护消费者的合法权益，规范经营者收集、使用在为消费者提供生产、销售商品或者提供服务的过程中取得的消费者个人信息的行为，消费者权益保护法延续了民法典的相关规定。无论是《中华人民共和国民法典》还是《中华人民共和国个人信息保护法》，均明确了保护个人信息权益以及促进个人信息合理利用的基本原则并规定侵害个人信息权益应依法承担法律责任。其遵循的原则是合法、正当、必要。合法，是指符合法律、法规等规定，不存在违反规定的地方，这里的法律法规，除消费者权益保护法外，还应当包括《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国个人信息保护法》等涉及个人信息的法律法规在内。正当，是指符合正常的情理和一般规则，这里涉及社会正常人的普通认知以及相应的惯例做法。必要，是指不可缺少，即不能超过必要的限度，在正常人的容忍范围内。

2. 收集使用信息的合法要件

根据规定，收集、使用消费者个人信息，应当需要满足两大要件：一是明示收集、使用个人信息的目的、方式和范围的义务；二是必须取得消费者同意，二者缺一不可。仅仅是经过消费者同意，但是未明示收集、使用目的、方式和范围仍应属于侵害消费者个人信息的行为。本案中，作为经营者一方的原告即抗辩称取得了消费者的同意，但从查明的事实看，经营者在收集信息时，并未明示收集、使用个人信息的目的、方式和范围，因此，仍然属于违反法律的情形。

3. 关于是否使用个人信息的认定

使用个人信息与使用信息是否取得相应的效果与结果是不同的概念，实践中需要注意进行区分。利用个人信息进行商业行为，如本案中的拨打电话、添加微信等行为，即属于使用行为，至于后续是否因为使用行为获得相应的商业

效果，并不能否定使用的认定。

国家对个人信息保护早已提上议程，并通过立法、修法相继颁布了配套的法律法规，共同编织成了一张消费者个人信息的“保护网”。但个人信息的主动保护意识并未能紧随法治的脚步，无论是公民个人还是相关企事业单位，对于个人信息的保护不够重视，尚未形成应有的法治氛围。个人信息包括个人姓名、家庭地址、通信方式等核心要素，一旦使用不当，极易引发相关的违法犯罪活动。个人信息泄露成为信息时代的痛点，无论是各行各业从业者、消费者个人还是负有个人信息保护职能的行政机关都应当肩负起相应的主体责任和法律责任。本案的处理，对于经营者在商业活动中收集使用相关个人信息时注意提高个人信息保护意识，把信息保护作为从事商业活动的重要前提和不可逾越的底线，作出了指引。同时，也对个人增强主动保护个人信息的责任意识以及行政机关强化行政监督责任起到了很好的警示作用。

编写人：江苏省南通经济技术开发区人民法院 潘雄博 李会利

现场即时采样的监测结果可作为判定污染物是否超标的证据

——某矿业有限责任公司诉某市河流水生态保护综合执法局罚款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省宜昌市中级人民法院(2023)鄂05行终210号行政判决书

2. 案由：罚款纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某矿业有限责任公司

被告(被上诉人):某市河流水生态保护综合执法局

【基本案情】

2022年7月12日，某市水生态保护综合执法局执法人员对某矿业有限责任公司位于某村一组的挑水河磷矿东部矿段909工区生活污水处理设施进行现场检查，并委托第三方检测机构对生活污水排口排水进行采样检测。根据第三方检测机构2022年7月18日出具的《检测报告》，污染物总磷浓度为4.5毫克/升、氨氮浓度为52.7毫克/升、悬浮物浓度为184毫克/升、化学需氧量浓度为333毫克/升，前述四项污染因子排放浓度均超过《关于挑水河磷矿东部矿段磷矿资源开发利用项目环境影响报告书的批复》核准的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准。某市水生态保护综合执法局经复核该矿业公司的申辩意见后，依法作出《行政处罚决定书》，决定对某矿业有限责任公司处以罚款22万元的行政处罚。

【案件焦点】

1. 某市水生态保护综合执法局以即时采样结果作为处罚依据是否合法；
2. 某矿业有限责任公司超标排污的行为是否属于轻微违法、应当或者可以不予处罚的情形。

【法院裁判要旨】

湖北省宜昌市西陵区人民法院经审理认为：能否依据即时采样结果进行处罚，实质既涉及污染物排放是否超标的事实判断，同时，也涉及法律适用的价值判断。一方面，即时采样的数值是污染物排放的真实数值，更接近排污是否超标的事实本身，而混合采样的数值可以理解为多次加权平均的模拟数值，更适合用来分析排污规律和趋势。简言之，相比混合样数值，即时采样数值作为排污是否超标事实判断的依据更为科学、准确。另一方面，从法律适用角度看，原国家环保总局于2007年2月27日发布《关于环保部门现场检查中排污监测方法问题的解释》明确：“根据有关法律的规定，排放标准具有强制实施的效力，必须执行。遵守排放标准是排污单位的法定义务。排放标准中规定的污染物排放方式、排放限值等是判定排污行为是否超标的技术依据，在

任何时间、任何情况下，排污单位的排污行为均不得违反排放标准中的有关规定。环保部门对排污单位进行监督性检查时，可以环保工作人员现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否超标以及实施相关环境保护管理的依据。”2010年3月1日起施行的环保部《环保行政处罚办法》第三十七条规定，环境保护主管部门在对排污单位进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。因此，无论是从生态环境保护立法初衷出发，或是考虑生态环境行政执法的可操作性，将即时取样的结果单独作为行政处罚依据符合行政法基本原则精神和《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定。

水污染所产生的污染后果及环境效应一般具有滞后性，往往在污染发生时不易被发现，但一旦污染后果发生就表示环境污染已经达到了相当严重的地步。本案中，某矿业有限责任公司生活污水排放的污染物经检测有4项因子超标，且总磷浓度超标倍数在10倍以上，对水环境产生了影响和破坏，已经造成了环境污染后果。不符合《湖北省生态环境轻微违法不予处罚专项清单(2021版)》中的情形。故，某矿业有限责任公司关于轻微违法应当或者可以不予处罚的意见，法院依法不予采纳。

因此，某市河流水生态保护综合执法局作出的案涉《行政处罚决定书》事实清楚，证据充分、程序合法、适用法律正确。

湖北省宜昌市西陵区人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回某矿业有限责任公司的全部诉讼请求。

某矿业有限责任公司不服，提出上诉。

湖北省宜昌市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

证据是可以用于证明案件事实的材料。能够反映案件真实情况、与待证事

实相关联、来源和形式符合法律规定的证据，应当作为认定案件事实的根据。《中华人民共和国行政处罚法》第五十六条规定，行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法。可见，抽样取证是行政机关在执法过程中调查收集证据的一种重要方式。

现场即时采样，是指现场检查时取一个样品进行监测，是生态环境执法过程中，尤其是判断污水是否超标排放、大气污染物排放是否超标时运用较多的一种取证方式，它对及时发现环境违法行为、客观反映违法排污的情形和情节，加大环境执法力度发挥着非常重要的作用。现场即时采样是抽样取证的一种特殊方式。

污染物排放是否超标，作为一个事实认定或事实判断，本质是何种检测数值代表排放数值更为科学的问题：多个样本平均值代表污染物排放数值更合理，或是每个瞬时样本数值都可以认定为排放数值？从排放数值的定义看，每个即时采样数值都代表污染物排放情况，若干数量的即时取样数值可以计算某一时段排放均值，数量足够的即时采样数值绘制的曲线可以得出排放规律。所以，即时采样数值就是污染物排放状况的真实体现。但从研究排污规律或计算排污平均值角度，混合样肯定要比一次即时采样更为科学、更能准确反映排污规律。考虑检测监测成本、操作可行性等现实因素，间隔2小时采样的混合取样应当是当前法规政策对采样频率与成本曲线的合理估算，以及对企业承受能力限度的平衡考虑。但伴随着检测监测技术进步、成本逐步降低，为了更及时、更准确掌握排污状况，即时采样势在必行。相比混合样数值，即时采样数值作为排污是否超标事实判断的依据更为科学、准确。

生态环境执法部门作为生态领域行政管理部门，肩负依法治污的职责，不论是行政管理的效率、管理成本需要还是生态环境严格保护制度要求，生态环境执法部门排污监督检查中依法即时采样监测是合法、有效、可操作执行的事实认定方式，该方式一定程度上减少相对人在固定时限内多次采样而“适时调整”客观排污数据的可能，即时采样监测与严格依法治污、推进生态优先、保护生态环境的大政方针的根本宗旨相符。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、《生态环境部关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》、《湖北省生态环境行政处罚裁量基准规定(2021年修订版)》第十二条第一款第二项规定以及《湖北省生态环境轻微违法不予处罚专项清单(2021年版)》来看,认定违法行为是否轻微,过错责任只是裁量要素之一,应从排污企业的排污时间、超标因子的数量及超标倍数等因素予以考量。本案中,某矿业有限责任公司生活污水排放的污染物经检测有4项因子超标,有的检测项目已超标数倍,在客观上对水环境水资源已经产生了影响和破坏。企业本该积极履行环保责任,却为了一己私利降低成本,超标排放污水。某市生态保护综合执法局依法对其作出行政处罚决定,是积极履行流域执法保护职责的具体体现。

编写人:湖北省宜昌市西陵区人民法院 张玲玲

行政机关纠正已经生效的行政处罚 应当基于正当事由并履行法定程序

——刘某某诉某市公安局交通管理局行政处罚案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省石家庄市中级人民法院(2023)冀01行终511号行政判决书

2. 案由: 行政处罚纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 刘某某

被告(被上诉人): 某市公安局交通管理局

【基本案情】

2022年6月13日21时许，刘某某驾驶轻型仓栏式货车，因涉嫌饮酒后驾驶机动车被执勤民警查获。刘某某现场酒精呼气测试结果为67毫克/100毫升，执勤民警制作了现场笔录，刘某某表示无异议并签字确认。2022年6月13日，交警大队对案件进行立案调查。2022年7月13日，交警大队向刘某某作出公安行政处罚告知笔录，告知刘某某拟作出行政处罚的事实、理由、依据及拟对刘某某进行行政拘留15日的处罚。刘某某未提出陈述申辩。2022年7月14日，某市公安局交通管理局作出《行政处罚决定书》（以下简称4号处罚决定），决定对刘某某罚款5000元整，行政拘留15日，并将该处罚决定送达刘某某。同日，某市公安局交通管理局出具另一份同编号的《行政处罚决定书》，决定对刘某某行政拘留15日，卷宗中无送达材料。2022年7月14日至29日，刘某某被执行拘留15日的处罚。

2022年8月15日，某市公安局交通管理局再次向刘某某作出行政处罚告知笔录，告知刘某某拟对其饮酒后驾驶营运机动车的违法行为进行处罚，但未告知拟作出处罚的种类。刘某某未提出陈述申辩，不申请听证。2022年8月26日，某市公安局交通管理局作出《行政处罚决定书》（以下简称3号处罚决定），罚款5000元，吊销机动车驾驶证。2022年9月7日，刘某某交纳罚款5000元。

刘某某认为某市公安局交通管理局作出的处罚程序违法，一事多罚，要求撤销2022年8月26日被告某市公安局交通管理局作出的3号处罚决定。

【案件焦点】

行政机关是否应当基于正当事由并履行法定程序纠正已经生效的行政处罚。

【法院裁判要旨】

河北省石家庄市桥西区人民法院经审理认为：《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第三款规定：“饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。”本案中，刘某某经现场呼气式酒精测试结果为67毫克/100毫升，构成饮酒后

驾驶营运机动车的违法行为，依法应当予以处罚。针对刘某某饮酒后驾驶营运机动车的违法行为，某市公安局交通管理局先后作出三份处罚决定。其中，2022年7月14日，某市公安局交通管理局作出的4号处罚决定，处罚内容为罚款5000元，行政拘留15日，该处罚决定书已向刘某某送达；2022年7月14日，某市公安局交通管理局作出的处罚决定书，处罚内容为拘留15日，该处罚决定书无向刘某某送达材料；2022年8月26日，某市公安局交通管理局作出的3号处罚决定，处罚内容为罚款5000元，吊销机动车驾驶证，该处罚决定书已向刘某某送达。某市公安局交通管理局于2022年7月14日作出了处罚内容为罚款5000元，行政拘留15日的行政处罚决定，该处罚决定已经送达且某市公安局交通管理局并未履行相关法律程序撤销该处罚决定书，因此该处罚决定书具有法律效力。该决定未被依照法定程序撤销的情况下，某市公安局交通管理局又于2022年8月26日作出行政处罚决定，两个生效处罚决定的罚款部分重复，违反了“一事不二罚”的规定，刘某某的诉讼理由成立。

河北省石家庄市桥西区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销某市公安局交通管理局于2022年8月26日作出的3号处罚决定；
 - 二、责令某市公安局交通管理局于法定期限内重新作出行政行为。
- 刘某某不服一审判决，提出上诉。

河北省石家庄市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

依法处罚饮酒后驾驶机动车的行为，保卫人民群众道路交通安全是交通管理部门的法定职责。交通管理部门须不断提高行政执法办案水平，避免因执法不规范导致执法效能折扣情况的出现。

为维护社会秩序稳定，行政处罚决定生效后具有确定力，其内容不得随意变更，具有相对稳定性。但是，有错必纠也是行政机关的法定义务。《中华人

民共和国行政处罚法》第七十五条第二款规定，行政机关实施行政处罚应当接受社会监督。公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政处罚的行为，有权申诉或者检举；行政机关应当认真审查，发现有错误的，应当主动改正。因此，为缓解行政处罚决定的效力稳定性和内容合法性之间的张力，需要行政机关在改正已经生效的行政处罚决定时更加谨慎，以正当事由为基础，综合考量改正过程中应当考虑的相关因素。

一、纠正行政处罚决定正当事由的确定

行政机关决定改正已经生效的行政处罚决定，应当基于正当事由，通常情况下以“错误”为认定应当改正的正当事由，而“错误”应当为事实认定错误或者法律适用错误，并不包含行政机关改变裁量权后使得行政决定更加“合理”的情形。例如，对饮酒后驾驶营运机动车的行为，应当作出15日拘留+5000元罚款+吊销机动车驾驶证+五年内不得重新取得机动车驾驶证的处罚。处罚决定书的内容与法定的处罚内容不一致时，出现处罚漏项的情况，属于法律适用错误，故基于正当事由应予以改正。而对于伪造机动号牌的违法行为，应当作出15日以下拘留+2000元以上5000元以下罚款的处罚，行政机关不能以违法行为危害性不大为由将15日拘留改正为14日拘留，损害行政处罚决定的确定力。当然，在“明显不当”的情况下，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第六项的规定应当予以撤销，行政机关在此情况下，依然应当以法律规定为准，主动改正“明显不当”的行政处罚决定。

二、纠正错误行政处罚决定的法定程序

对于已经生效的行政处罚决定，行政机关确实需要予以纠正的，应当履行法定的程序。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第五章第三节关于行政处罚的普通程序规定，行政机关作出行政处罚需要经过立案、调查、告知陈述申辩权利、作出处罚决定并送达等重要程序。行政机关纠正错误行政处罚决定的程序因对当事人权利义务产生重大影响，故而也应当履行法定程序，包括：调查程序以查明是否有必要撤销原决定及如何重新作出决定；告知陈述申辩的权利以保障案

件的公正处理；送达程序以保障撤销决定和新决定的生效等。

三、作出新的行政处罚决定应以撤销原行政处罚决定为前提

已经生效的行政处罚决定，非经法定的撤销程序予以撤销的，仍然为生效决定，在此基础上，行政机关再次作出新的处罚，构成重复处罚。即使两次处罚内容不相同，由于新处罚决定所依据的事实与原处罚决定相同或者基本一致，两次处罚叠加于行政相对人，实质上仍然是行政机关针对行政相对人的同一违法行为予以重复处罚，违反“一事不再罚”原则。

本案中，行政机关认为4号处罚决定错误需要予以纠正，但是在未撤销该处罚决定的情况下，又针对同一违法行为作出3号处罚决定，导致对当事人的同一违法行为给予了两次罚款，违反了《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚”的规定，应当予以撤销。

编写人：河北省石家庄市桥西区人民法院 王清正 郭雨佳 齐立霞

营销推广性质的扫码免费赠与商品属于经营行为

—— 某品种盐公司蒙城分公司诉某县市场监督管理局罚款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省亳州市蒙城县人民法院(2022)皖1622行初18号行政判决书

2. 案由：罚款纠纷

3. 当事人

原告：某品种盐公司蒙城分公司

被告：某县市场监督管理局

【基本案情】

2020年1月8日，某品种盐公司蒙城分公司从某品种盐公司调拨“××牌”深井岩盐104件，规格为每件60袋，每袋320克，表明生产日期为2018年1月30日，注明保质期36个月，因包装箱破损，另赠送“××牌”深井岩盐16件。2020年7月某品种盐公司蒙城分公司将104件“××牌”深井岩盐销售给蒙城某某超市。剩余16件食盐，某品种盐公司蒙城分公司于2021年4月25日赠送给任某某、李某某各1件，4件(240袋)同日在蒙城某博览会以0.33元/袋的价格销售，另有584袋以扫码免费赠送的方式送出，剩余16袋被某县市场监督管理局查获扣押。2021年4月26日，某品种盐公司蒙城分公司发出公告，告知参与2021年4月25日在广场赠送食盐的消费者，受赠食盐需召回。2021年8月10日某县市场监督管理局作出行政处罚决定，认定某品种盐公司蒙城分公司违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一项、第十项之规定，构成经营超过保质期食品的行为。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项的规定，结合《安徽省市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规则(试行)》第十四条决定对某品种盐公司蒙城分公司处罚如下：(1)没收超过保质期的××牌深井岩盐16袋；(2)没收违法所得79.2元；(3)罚款86000元。某品种盐公司蒙城分公司不服，提起行政诉讼，请求撤销上述处罚决定。

【案件焦点】

1. “扫码免费赠与过期食盐”的行为是否属于食品安全法中的经营行为；
2. 某县市场监督管理局的处罚是否适当。

【法院裁判要旨】

安徽省亳州市蒙城县人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款规定：“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。”第六条“实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守

法。”第三十二条“当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的……（五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的”以及《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准（2020本）》相关规定。本案原告低价销售和赠送的部分食盐由于受客观因素影响，超过了保质期，在被查处时，原告积极配合，如实陈述违法事实，主动提供进货来源并主动采取召回措施消除危害后果。被告依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项、《安徽省市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规则（试行）》第十四条对原告处以86000元罚款，在处罚幅度上明显不当。故，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准（2020本）》的规定，应当予以减轻处罚，结合违法情节及社会危害后果，本院依法将罚款数额变更为30000元。

安徽省亳州市蒙城县人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十七条的规定，判决如下：

一、变更被告某县市场监督管理局作出的行政处罚决定书第三项中“处86000元罚款”为“罚款30000元”；

二、驳回原告某品种盐公司蒙城分公司的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

某品种盐公司蒙城分公司的“扫码免费赠与过期食盐”属于“经营行为”是某县市场监督管理局适用《中华人民共和国食品安全法》处罚的前提。而经营行为不只是买卖行为，“扫码免费赠与过期食盐”的行为是否应认定为“经营行为”应以是否具有产生市场有利效果的目的综合判断。在具有推广宣传性质的展销会上设有摊位，以扫码方式赠与食盐，是面向消费者对其商品和品牌的宣传行为，具有推广营销的性质，有利于扩大市场上的商标知名度，能产生增加经济利益的影响。同时免费获赠的人也需扫码关注，推广营销行为所面向的市场客体附加了交换义务，使得经营者扩大知名度、获得目标客户的营销目

的得以实现。故，赠与行为并非单纯的好意施惠，免费获赠的人实际上仍是消费者身份而非单纯的获益人。综上，“扫码免费赠与过期食盐”应认定为食品安全法中的经营行为。

本案某县市场监督管理局在接到某品种盐公司蒙城分公司销售过期食盐的举报后，对案件进行了立案、现场调查、询问并履行处罚前告知、听证等程序，某县市场监督管理局认定某品种盐公司蒙城分公司销售和赠与超过保质期的食盐事实清楚，程序合法。某品种盐公司蒙城分公司低价销售和赠与的部分食盐由于受客观因素影响，超过了保质期，在被查处时，某品种盐公司蒙城分公司积极配合，如实陈述违法事实，主动提供进货来源并主动采取召回措施消除危害后果。某县市场监督管理局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项、《安徽省市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规则(试行)》第十四条对某品种盐公司蒙城分公司处以86000元罚款，在处罚幅度上明显不当。《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款规定：“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。”是合理性原则的体现。行政处罚法是普通法，食品安全法是特别法，二者是普通法和特别法的关系，通常情况下应优先适用食品安全法，在食品安全法没有明确规定时，可以适用行政处罚法的有关规定。在行政相对人被查处时，如果有积极配合，如实陈述违法事实，提供进货来源并主动采取召回措施有效消除危害后果的行为，行政机关应依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，结合违法情节及社会危害后果，予以减轻处罚。故，法院根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准(2020本)》的规定，结合违法情节及社会危害后果，依法将罚款数额变更为30000元。

编写人：安徽省亳州市蒙城县人民法院 井飞雪 郭璇

责令停止供气工作函属于行政诉讼受案范围的认定标准

——宋某某诉某街道办事处责令停止供气案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2022)京01行终911号行政判决书

2. 案由：责令停止供气纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):宋某某

被告(上诉人):某街道办事处(以下简称街道办)

第三人(被上诉人):石油气公司

【基本案情】

某餐厅系个体工商户，其经营者登记为段某某。2022年3月19日，段某某因病去世。宋某某系段某某之子。2021年6月22日，某餐厅与石油气公司签订《北京市非居民瓶装液化石油气供用合同》，由石油气公司向该餐厅提供瓶装液化石油气。2021年9月28日，街道办向石油气公司出具《某街道办事处关于请石油气公司配合政府对违法建设用气客户实施停止供气工作的函》(以下简称停止供气工作函)，主要内容为：根据某区治违办的工作要求并结合辖区实际情况，依据《北京市城乡规划条例》及《北京市禁止违法建设若干规定》等法律法规，街道办于2020年10月份对xx路×号×排、×排违法建设情况进行调查，经调查上述四处建筑物总建筑面积共83.33平方米，未依法取得建筑工程规划许可证。经现场走访，该四处房屋均有住人且有重大安全隐患，该处房屋为贵公司

提供非居民瓶装液化石油气客户，用户名称为某餐厅。为保证全面消除安全隐患，并保证拆除过程安全，请石油气公司配合街道办尽快对违法建设用电客户实施停止供气工作。附件：关于x×路×号×排、×排所建建筑物规划审批情况的函。

2021年9月30日，石油气公司停止向某餐厅供应液化石油气。宋某某作为某餐厅的实际经营者不服，向法院提起行政诉讼，请求法院查清事实，确认街道办自2021年9月30日至10月10日以违法建设的名义要求石油气公司对宋某某的某餐厅实施停止供应液化石油气的行政行为违法。

【案件焦点】

1. 街道办作出的停止供气工作函是否属于行政指导行为；2. 停止供气工作函是否产生了外部化的效果，是否具有可诉性。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：本案中，街道办于2021年9月28日向石油气公司作出停止供气工作函，要求石油气公司配合街道办对某餐厅实施停止供气相关事宜。石油气公司于2021年9月30日停止向某餐厅供气。尽管上述停止供气工作函是街道办向石油气公司作出的，街道办并未直接向某餐厅作出停止供气工作函，但该函的内容涉及对涉案建筑停止供气问题，某餐厅又是与石油气公司就涉案建筑签订了《北京市非居民瓶装液化石油气供用合同》的用气人，且石油气公司依据停止供气工作函对涉案建筑停止了供气，因此街道办作出停止供气工作函的行为对某餐厅的权利义务产生了实际影响，该行为依法属于行政诉讼的受案范围。同时，宋某某作为某餐厅的实际投资人、实际经营者，其权利义务受到该行为的实际影响，其与该行为具有利害关系，依法具有针对该行为提起行政诉讼的主体资格。

《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条规定，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。如果被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。本案中，街道办向石油气公司作出停止供气工作函，认定某餐厅所属房屋未取得建筑工程规划许可证，

系违法建设，要求石油气公司配合街道实施停止供气工作，但街道办并未向法院提交认定某餐厅所属房屋为违法建设并据此停止供气的相关证据材料，其作出的停止供气工作函明显属于认定事实不清，主要证据不足，应予纠正。

综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决如下：

撤销某街道办事处向石油气公司作出的《某街道办事处关于请石油气公司配合政府对违法建设用气客户实施停止供气工作的函》。

街道办不服，提出上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系街道办为实施拆除违法建设行为，向石油气公司发送停止供气工作函，要求石油气公司对某餐厅实施停止供气行为而引发的行政争议。街道办主张，停止供气工作函属于拆除违法建设前的过程性行为及行政指导行为，不具有行政强制力及可诉性，不属于行政诉讼的受案范围。鉴于此，停止供气工作函是否属于行政诉讼受案范围成为本案首要解决的问题。

一、街道办作出的停止供气工作函并非行政指导行为

行政指导，是指行政机关在其所管辖事务的范围内，对于特定的公民、企业、社会团体等，通过制定诱导性法规、政策、计划、纲要等规范性文件以及采用具体的示范、建议、劝告、鼓励、提倡、限制等非强制性方式，并辅之以利益诱导促使相对人自愿作出或不作出某种行为，以实现一定行政目的的行为。如果行政机关以行政指导的形式，作出了发生行政法律关系的意思表示或者在事实上影响了行政相对人的合法权益的行为，那么这种行为就不再是行政指导行为。当事人对此种行为不服，可以向人民法院提起行政诉讼。^①

^①最高人民法院行政审判庭编著：《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用》〔上〕，人民法院出版社2018年版，第49页。

行政机关作出的行政行为，并不因为具有行政指导行为的外观而免除司法审查，是否属于行政诉讼受案范围需要坚持“对当事人权利义务产生实际影响”为标准进行判断。

本案中，街道办作出的停止供气工作函不是行政指导行为，主要理由如下：(1)该函是要求相对人石油气公司为特定行为，即要求石油气公司尽快对某餐厅实施停止供气行为，配合街道办完成拆除违法建设工作，具有指令性。(2)从内容看，该函认定涉案四处建筑为违法建设，并认定四处建筑均住人且具有重大安全隐患，同时确定了实施停止供气的时间。(3)从效果看，实施停气的目的是保证消除安全隐患，并保证拆除房屋过程安全。因此，街道办作为行政机关，以停止供气工作函的形式，要求石油气公司对某餐厅实施停止供气行为，显然具有行政指令性质和强制色彩。上诉人作为某餐厅的实际投资人和经营者，石油气公司依据停止供气工作函对该餐厅停止供气，该餐厅无法经营的后果必定对投资人和经营者的权益产生实际影响。石油气公司实施停气行为并非该公司的意志，实质上对上诉人权益产生影响的行为是街道办通知石油气公司停气的行为，造成的法律后果应当由作出指示命令的街道办来承担。此外，街道办在停止供气工作函中直接认定涉案建筑为违法建设，亦直接影响了上诉人的权利义务。因此，街道办作出的停止供气工作函属于行政诉讼受案范围。

二、街道办作出的停止供气工作函已经产生了外部化的法律效果，对上诉人的权益产生了实际影响，具有可诉性

所谓多阶段行政行为，是指行政机关作出行政行为，须有其他行政机关批准、附和、参与始能完成之情形。各行政机关之间，既可能是平行关系，也可能是垂直关系。后者一般如下级机关的行政行为须经上级机关批准才能对外生效，或者上级机关指示其下级机关对外作出发生法律效果的行政行为。在存在复数行政行为的情况下，只有直接对外发生法律效力的那个行为才是可诉的行政行为，其他阶段的行政行为只是行政机关的内部程序。行政机关在实施多阶段行政行为的过程中，各行为之间通常存在先后顺序，有的行为之间具有程序

上的递进关系、有的行为之间具有要件上的构成关系，有的行为之间具有执行上的依据关系。就多阶段行政行为的可诉性而言，直接对外发生法律效力、直接对相对人权利义务产生实际影响的行政行为具有可诉性，过程性行为一般不具有可诉性。但如果过程性行政行为外化，对当事人的权利义务产生了实际影响，则具有可诉性。行政审判实践中，过程性行政行为外化主要表现在以下几个方面：一是通过行政机关法定的送达程序获知；二是通过行政机关具体的执行行为获知；三是通过其他正当途径获知等。

查处违法建设涉及一系列行为，属于多阶段行政行为。《北京市禁止违法建设若干规定》第三条规定，区人民政府领导本行政区域内城乡规划的实施，组织、协调、监督违法建设制止和查处工作，将制止和查处违法建设情况纳入相关考核。街道办、乡镇人民政府根据职责具体组织、协调本行政区域内违法建设的制止和查处工作。在街道办查处违法建设的过程中，往往需要协调多个主体相互之间的行为。就本案而言，街道办作出的停止供气工作函是其拆除违法建设过程中的一个行为，可能会被最终的拆除违法建设行为所吸收，并不对外发生法律效力。但在石油气公司依据停止供气工作函对某餐厅实施停止供气行为后，街道办并未实施后续的拆除违法建设工作，也未作出与停止供气相关联的其他行政行为。也就是说，石油气公司的停止供气行为没有被街道办后续的行政行为所吸收覆盖，变成了一种独立的行政事实行为。街道办作出的停止供气工作函和石油气公司停止供气行为之间形成了执行上的依据关系，停止供气工作函已经实际执行并对外发生法律效力，对上诉人的合法权益产生了实际影响，属于内部行政行为效力外部化。起诉人对停止供气工作函的作出行为提起诉讼，属于行政诉讼的受案范围。

编写人：北京市第一中级人民法院 梁菲 王素南

肇事后虽将伤者送至医院，但未接受交通管理部门 处理自行离开应视为交通肇事后逃逸

——李某诉某县公安交通警察大队罚款及暂扣许可证件案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

辽宁省锦州市中级人民法院(2023)辽07行终53号行政判决书

2. 案由：罚款及暂扣许可证件纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 李某

被告(被上诉人): 某县公安交通警察大队

【基本案情】

2022年7月30日，在某县东外环路十字路口南200米，李某驾驶小型普通客车由北向南行驶时，与行人杨某华发生碰撞，致杨某华受伤。事故发生后，李某将伤者杨某华送医后未报警，离开事故现场并关机。时隔两日，2022年8月1日，李某到某县公安交通警察大队接受询问，某县公安交通警察大队于2022年8月30日向李某作出公安交通管理行政处罚决定书和公安交通管理行政强制措施凭证，处以2000元罚款，记12分，扣留机动车驾驶证。李某不服上述行政处罚，提起行政诉讼。

【案件焦点】

李某肇事后虽将伤者送至医院，但未接受交通管理部门处理自行离开的是

否应视为“交通肇事后逃逸”。

【法院裁判要旨】

辽宁省黑山县人民法院经审理认为：首先，李某作为发生交通事故的车辆驾驶人违反了法定的义务。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条的规定，发生交通事故后车辆驾驶人具有立即采取必要措施保护现场、抢救伤员以及迅速报案的法定义务。具体到本案，李某在伤员已经有120救护车运送并有两位成年朋友随行，其完全可以报案并保护现场等待处理，其离开事故现场并于事故发生之后第三日投案，妨碍民警正确认定事故责任，属于未正确履行法定义务。其次，李某的行为符合交通肇事后逃逸的规定。本案中，李某及其朋友虽将伤者送到医院，但未报案亦未给伤者或家属留下姓名、联系方式，亦无向交通警察迅速报告、听候处理、配合调查，其无故离开医院，已经构成对法律责任的逃避履行，应视为交通肇事后逃逸。最后，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第三项规定，造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的，由公安机关交通管理部门处200元以上2000元以下罚款。本案中，某县公安交通警察大队依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》第三十九条规定，处2000元罚款；依据《道路交通安全违法行为记分管理办法》第八条规定，一次记12分；依据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十四条规定，扣留机动车驾驶证。上述处理行为认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，并无不当。

辽宁省黑山县人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

驳回李某的诉讼请求。

李某不服一审判决，提出上诉。

辽宁省锦州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“交通事故后逃逸”是指行为人在发生事故后逃跑的行为，但实践中，行

为人在交通事故后现场隐匿、冒名顶替、借故离开，形式变化多样，导致事故调查处理无法正常开展，受害人的权益得不到及时、有效的保护，能否认定为“交通事故逃逸”存在争议。对此刑法学者将交通肇事逃逸视为交通肇事罪的加重量刑情节，关于交通肇事逃逸的理论学说主要为“逃避法律追究说”和“逃避救助义务说”。前者认为，行为人明知自己造成了重大交通事故，并且具有逃避法律责任的目的，属于逃逸。^①后者认为，只要行为人第一时间救助了伤者，离开现场的行为就不属于逃逸。^②笔者认为，“交通事故后逃逸”应当区分行政违法与刑事违法，与刑法不同，行政管理中的“交通事故后逃逸”并非行政处罚的加重情节而是构成要件，其强调的是行政责任而非因果构成，如本文案例，李某肇事后将伤者送至医院后自行离开是否属于“交通事故后逃逸”，关键要看行为人主观上是否存在逃避法律追究的故意，客观上是否拒绝履行救治伤者及配合公安机关交通管理部门调查的义务。

一、“交通事故后逃逸”行为定性的法理依据

“交通事故后逃逸”在民法典和道路交通安全法中没有定义，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条表述为：“发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。”《道路交通事故处理程序规定》第一百一十二条第一项中表述为：“发生道路交通事故后，当事人为逃避法律责任，驾驶或者遗弃车辆逃离道路交通事故现场以及潜逃藏匿的行为。”该行政规章中对于逃逸的认定是为了遏制事故发生后行为人不尽保护现场、抢救受伤人员、报警并接受处理的义务，与刑法为制裁行为人逃避法律追究致使被害人因得不到救助而伤亡的管理目的明显不同，行政管理范畴的逃逸和刑法救助范畴的逃逸不能一概而论。行政法意义上“交通事故后逃逸”的要件是行为人具有主观故意即逃避法律责任，客观体现为驾车逃逸、弃车逃逸以及潜逃藏匿。关于驾车逃逸、弃车逃逸属于通说逃逸行为，其行为表现明显，认定主观具有逃

^①邹兵建：《论交通肇事罪中的逃逸问题》，载《法治现代化研究》2020年第6期。

^②张明楷：《将人送到医院后逃跑，属于交通肇事后逃逸吗？》，载《人民法院报》2022年5月。

避法律责任的目的不存在障碍。但关于“潜逃藏匿”行为，由于客观事实纷繁复杂，主观目的隐蔽性强，如何从事实行为推定主观目的是司法实践中的难题。

二、“潜逃藏匿”行为法院裁判应把握的重点

打击“潜逃藏匿”行为的宗旨是为了维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，故对其辨析应当重点把握行为人是否具有法定义务，是否拒绝履行法定义务，该拒绝行为是否导致了事故调查处理无法正常开展，受害人的权益得不到及时、有效的保护。

首先，行为人义务由法律规制，无正当理由不能拒绝。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条的规定，事故发生后，行为人的法定义务就是保护现场、抢救受伤人员、报警并接受处理。

其次，行为人明确和默示拒绝行为均构成不履行法定义务。如不履行现场保护义务，擅自变动现场的，但因抢救受伤人员并标明位置的除外；如不履行救治伤员义务，无故离开现场未报警或者报警后失联的，但肇事者担心被伤者亲属责难临时躲避，或者为救助伤者去周边寻求帮助等原因暂时离开现场的除外；如不履行报警并接受处理义务，在事故现场躲藏、指使、同意他人冒名顶替、否认侵害行为不接受和配合调查、将受伤人员送至医院后离开，没有留下真实姓名和联系方式的，但之后报警及时交代的情况除外。无论行为人出于何种心态，其冷漠的态度和不良的陋习违背中华民族的传统美德，背离了社会主义核心价值观价值体系，增加了被害人生命财产损失的风险，不应被肯定。

最后，行为人不履行法定义务行为与社会秩序的混乱之间需存在因果关系，进而推定其行政归责性。如本文案例，李某作为肇事者，其在事故现场已经拨打120急救电话，伤员已经有120救护车运送并有李某的两位成年朋友随行，其完全可以报警、保护现场并等待处理，离开事故现场不具有必要性。李某在医院没有给伤者留下联系电话，未及时联系警察，而是时隔两日后投案，该行为不利于警察及时固定、提取证据材料和正确认定事故责任，无法排除是否存在故意犯罪、醉酒、吸毒等加重情节，加大案件的侦破难度，妨碍了正常的社会管理，与社会秩序的混乱存在因果关系，具有逃避法律责任的主观恶性，虽

然对于伤者进行了救治但亦应当认定构成行政法意义上的“交通肇事后逃逸”。

三、“交通事故后逃逸”的教育和惩罚

“交通事故后逃逸”是以破坏秩序，挑战公德，躲避责任，拒绝文明为内容的陋习，为防止对我们的经济建设和社会发展产生负面作用，对其准确性并适当处罚符合正当性、必要性。当然，行政处罚不是目的，是通过行政责任的认定充分发挥惩戒、警示教育作用的一种手段。行政法意义上的“交通事故后逃逸”不限定逃逸的时间和场所，对于肇事后未逃离事故现场，将伤者送至医院后或者等待交通管理部门处理的时候自行离开的视为交通肇事后逃逸，不违反教育和处罚相结合的原则，有助于明确行为人的法定责任，便于公安机关交通管理部门在今后工作中查清事故责任和及时调查取证，从而杜绝漠视伤者救助、逃避法律责任的陋习。面对交通事故，行为人需要理性审视、明智取舍，摆脱束缚人们思想、制约社会发展的陋习，珍视和传承中华优秀传统文化中的精华，赋予其新时代价值，追求更加公正、和谐、法治的社会状态。

编写人：辽宁省锦州市中级人民法院 王锦鹏

教师对学生实施教育惩戒行为失当违反 治安管理处罚法的，公安机关需对其进行治安处罚

—— 张某某诉某市人民政府行政复议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

黑龙江省高级人民法院(2023)黑行终508号行政判决书

2. 案由：行政复议纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):张某某

被告(上诉人):某市人民政府(以下简称某市政府)

第三人(上诉人):芦某

第三人:某市公安局某分局

【基本案情】

2021年9月,芦某在某艺术学校教室内检查素描作业时,认为张某某完成作业不认真,将其叫到讲台附近后进行询问并实施殴打,造成张某某左侧外耳道充血,左耳鼓膜略充血。2021年10月,某市公安局某分局作出行政处罚决定,认定芦某殴打他人,依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款规定,决定对芦某处行政拘留五日并处罚款两百元。芦某不服该处罚决定向某市政府申请行政复议。2021年12月,某市政府作出复议决定,以某市公安局某分局作出的处罚决定适用依据错误为由,撤销该处罚决定。张某某不服,提起本案诉讼,请求撤销该复议决定。

【案件焦点】

教师在对学生进行教育管理的过程中对学生实施体罚的行为是否属于治安管理处罚法的调整范围。

【法院裁判要旨】

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院经审理认为:公安机关作为治安管理行政执法机关,对于涉及违反治安管理行为的举报、控告,应当依法进行调查,查明是否属于职务行为,若属于职务行为,是否有适用治安处罚的法律指引,进而准确适用法律,作出处理。教师超出正常履职范畴而对学生实施的殴打、伤害行为,则属《中华人民共和国治安管理处罚法》的管辖范围,并非只要具有了教师身份,其在教学时间和教学场所针对学生实施的殴打、伤害行为,就理应被评价为教师“体罚”学生,从而就不受《中华人民共和国治安管理处罚

法》的管辖。本案中，芦某与张某某均处于教学时间和教学场所，事发之前以及事发时，张某某都未有扰乱正常教学秩序或是不服管教、违反学校纪律等不当行为。事发时，教学场所内的教学活动正在正常进行，张某某作为学生完成并上交了素描作业，服从了芦某要求其到讲台附近的指令并如实回答了芦某提出的问题。芦某称其实施殴打行为的目的是管教张某某，但其在实施殴打行为前，并未对张某某进行较为缓和的言语教导或批评等在教学中更为常见和适当的教导，而是直接进行了殴打。而且，不仅没有证据证明事发时张某某存在需要教师进行惩戒的行为，也没有证据证明芦某殴打张某某是为了履行教育与管理职务而采用的惩戒手段以及其并不具有殴打和伤害张某某的故意。据此，案涉复议决定关于“现有证据能够证明芦某在对学生张某某进行教育管理的过程中存在体罚学生行为，申请人的行为属于履行职务不当，依法应予处分，不属于《中华人民共和国治安管理处罚法》的管辖范围”的认定，属认定事实不清、证据不足，适用法律错误。

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销某市政府2021年12月17日作出的案涉复议决定；
 - 二、某市政府于判决生效之日起六十日内重新作出行政复议决定。
- 某市政府、芦某不服，提出上诉。

黑龙江省高级人民法院经审理判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

行政相对人的同一违法行为违反不同行政管理秩序、不同行政法律规范设定不同行政处罚的，有处罚权的行政主体如何处理以及复议机关或司法机关如何进行法律评价。下面将以本案中教师“体罚”学生行为为例，对该问题予以具体阐释。

一、教师“体罚”学生可能侵犯的法益

教师在履行教育职责过程中，为了维护正常的教学秩序，可以对违规违纪

学生进行管理、训导和矫治等教育惩戒,但不应超过教育管理的合理边界。《中华人民共和国教师法》第三十七条第一款规定,教师体罚学生,经教育不改的,由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。由此可见,教师超过教育管理的必要限度对学生实施“体罚”,违反了法律和职业道德,侵犯了正常的教育管理秩序。同时,构成“殴打他人”并造成了被“体罚”学生的人身损害,亦侵犯了治安管理秩序。

二、《中华人民共和国治安管理处罚法》与《中华人民共和国教师法》的法条竞合与排他适用

教师“体罚”学生,同时违反了教育管理秩序和治安管理秩序,因此同时属于《中华人民共和国治安管理处罚法》与《中华人民共和国教师法》的调整范围。有处罚权的行政机关需根据违法行为的性质、程度、损害后果以及是否有不予处罚、从轻、减轻情节,在法定处罚幅度范围内作出行政处罚决定。本案中,复议机关认为教师芦某体罚学生张某某系违反教育管理秩序的行为,应适用教师法对其进行校内处分,不应由公安机关依据治安管理处罚法作出治安处罚决定,存在法律适用错误。教师超出正常履职范畴而对学生实施的殴打、伤害行为,仍应受到《中华人民共和国治安管理处罚法》的调整。人民法院在对教师惩戒学生行为进行评价时应当充分考量行政主体、被侵害法益以及惩戒行为是否超过必要限度等因素,并非只要具有教师身份,其在教学时间和教学场所针对学生实施的殴打、伤害行为,就理应被评价为教师“体罚”学生,从而豁免于治安处罚。

三、假使教育主管部门依据《中华人民共和国教师法》对芦某作出处罚,是否违反“一事不两罚”原则

教师芦某“体罚”学生张某某事件中,仅某市公安局某分局对其作出的行政处罚决定进入行政复议和行政诉讼程序。假设学校或教育局在公安机关对芦某进行治安处罚后又依据教师法第三十七条规定对芦某进行处分,是否违反“一事不两罚”原则?笔者认为,答案是否定的。第一,《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条规定,对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚

款的行政处罚。对于教师“体罚”学生的行为，治安管理处罚法规定了行政拘留和罚款，系人身罚和财产罚；而教师法规定的行政处分或者解聘，系行为罚或申诫罚，二者并不属于相同的处罚种类，因此并不受“一事不两罚”原则的限制。第二，行政处罚设立“一事不两罚”原则，原因在于行政处罚的功能和目的不仅在于惩戒，更在于教育，因此应当保持谦抑审慎、不得滥用。如果一次处罚即可达到目的，就不宜再对相对人进行另外的处罚。但本案中，由于治安管理处罚法和教师法对于教师“体罚”学生行为规定的处罚种类并不相同，惩戒和教育目的也并不相同，故二者适用并不排他。教师超过必要限度对学生实施惩戒行为，构成“体罚”的，学校或教育主管部门需依据教师法相关规定对违法行为人进行处分，同时构成殴打他人的，公安机关得依据治安管理处罚法对违法行为人作出行政拘留或罚款等治安处罚决定。

编写人：黑龙江省高级人民法院 赵良宇 王乔

二、行政强制执行

14

违法建筑案件中行政机关与行政相对人 混合过错中的信赖利益认定

—— 陈某某诉某县某镇政府强制拆除房屋及行政赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08行终213号行政判决书

2. 案由: 强制拆除房屋及行政赔偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某某

被告(被上诉人): 某县某镇政府

【基本案情】

2017年年底, 陈某某向案外人方某某(后因非法倒卖土地使用权罪被判刑)购买某县某镇国道与通往高速路口道路夹角的某社区70平方米集体土地作建房用地, 陈某某与方某均非该集体经济组织成员。根据《某县某镇总体规划》(2013年11月), 建房地块属远期发展备用地, 根据《某县某镇土地利用总体规划图》, 属于限制建设区, 建房不符合土地利用总体规划。某镇国规站时任负责

人王某某(后因滥用职权罪、受贿罪被判刑)滥用职权,违反规定以某镇国规站的名义为陈某某颁发落款为2017年1月26日的《乡村建设规划许可证》。

自2019年起,某县某镇政府发现不断有群众在上述地段建房,在无法准确调查建房户主信息的情况下,2019年12月,某县某镇政府以“某镇某小区建房户”为对象下发《停工通知书》《限期拆除通知书》。2020年1月、4月,某县自然资源局、平南县住房和城乡建设局以“某地段范围内所有建房户”为对象分别下发《责令停止违法行为通知书》。2020年12月,某县自然资源局对陈某某非法买卖土地建房行为立案调查并责令停止违法行为。2021年3月8日,某县自然资源局对陈某某非法买卖土地建设房屋行为作出行政处罚,限定陈某某在15日内自行拆除在非法转让的土地上新建的房屋,恢复土地原状;并处非法转让土地罚款8400元。2021年6月3日,某县某镇政府在建房户墙壁及当地显眼地段张贴《通告》,内容为某社区某地段的建筑均未取得完全合法建设手续,属违法建筑。根据相关规定,现责令上述各建房户于通告发布之日起5日内将违法建筑自行拆除,逾期不拆除的,相关部门将依法强制拆除,因此引发的损失自行承担。但包括陈某某户在内的各建房户均没有自行拆除。

2021年10月18日,某县自然资源局认定陈某某所持的《乡村建设规划许可证》属某镇国规站越权发放,撤销了该证。2021年10月19日,某县某镇政府组织力量强制拆除了包括陈某某户在内的建(构)筑物共67间。2020年8月陈某某开始建设房屋,2021年10月19日陈某某房屋被强制拆除时,房屋建到两层,面积为175平方米,陈某某房屋旁堆放有少量红砖,数量无法查清。陈某某认为某县某镇政府的强制拆除行为损害其合法权益,遂提起本案行政诉讼,请求:(1)判决确认某县某镇政府于2021年10月19日拆除陈某某房屋行为违法;(2)判决某县某镇政府赔偿陈某某经济损失239768元;(3)本案诉讼费由某县某镇政府承担。

【案件焦点】

1. 行政机关颁发建设规划证又撤销证件是否存在信赖利益;2. 某镇政府拆除违法建筑是否赔偿损失。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区平南县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国土地管理法》第七十四条规定，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状。

《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区农村宅基地审批管理办法的通知》第三条第二款规定，市、县(市)国土资源行政主管部门负责农村宅基地申请的审核并报有权审批的人民政府审批。第七条规定，村民申请宅基地应当向市、县(市)国土资源行政主管部门提出，由有批准权的人民政府审批。具体程序为：(1)村民向村(居)民小组提出申请，填写《广西壮族自治区农村居民建设住宅用地申请表》；(2)村(居)民小组讨论同意后报村(居)民委员会，经村(居)民委员会同意并在村(居)民小组内公示15日，无异议后报乡(镇)国土资源所、乡(镇)人民政府审核；(3)乡(镇)人民政府审核同意后，由市、县(市)国土资源行政主管部门审核报市、县(市)人民政府批准；(4)农村宅基地经有批准权的人民政府批准后，由市、县(市)国土资源行政主管部门核发《农村宅基地建设用地批准通知书》，由村(居)民小组或村(居)民委员会将审批结果在当地张榜公布。《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条第三款、第四款规定，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建设，不得占用农用地；确需占用农用地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》有关规定办理农用地转用审批手续后，由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后，方可办理用地审批手续。《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》

第三十八条规定，村民在乡、村庄规划区范围内进行住宅建设的，应当办理乡村建设规划许可证。不属于使用原有宅基地建造住宅的，由乡镇人民政府提出初审意见，报上一级人民政府城乡规划主管部门审定、核发乡村建设规划许可证。

关于某县某镇政府是否有权对涉案房屋采取强制拆除措施的问题。根据

《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条规定，在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。某县某镇政府依法具有对辖区内房屋采取强制措施的职权。陈某某用于建设房屋的地块属于某镇某社区集体所有，根据《某县某镇总体规划》（2013年11月），建房地块属远期发展备用地，根据《某县某镇土地利用总体规划图》[2010—2020年（2015年调整）]，属于限制建设区，建房不符合土地利用总体规划。某县某镇政府有权对涉案房屋采取强制措施进行拆除，其执法依据属法律授权。

关于某县某镇政府强制拆除陈某某房屋行为是否合法的问题。本案中，某县某政府对涉案房屋有权实施行政强制措施予以拆除，但该行为应当遵守《中华人民共和国行政强制法》第十八条的相关规定。而某县某镇政府在对案涉房屋采取强制措施予以拆除时，没有制作现场笔录，在当事人不到场时没有邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章等，确实存在程序违法之处。

关于某县某镇政府是否需要承担赔偿责任的问题。《中华人民共和国国家赔偿法》第二条第一款规定，国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。第四条第二项规定，违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的，受害人有取得赔偿的权利。根据上述法律规定，只有国家机关和国家机关工作人员行使行政职权被确认违法，且该违法行为对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害时，才产生行政赔偿。本案中，陈某某在未依法取得用地审批，未依法取得规划部门颁发的建设许可情况下建造房屋，涉案房屋依法不能认定为其受法律保护的合法财产，陈某某请求赔偿房屋损失，本院依法不予支持。某县某镇政府在实施被诉强制拆除时有义务关注并保护陈某某的合法财产。本案中，某县某镇政府虽然制作了《限期拆除通知书》，但某县某镇政府在实施强制拆除陈某某房屋行为时，将堆放在房屋旁尚

未用于建设的红砖一并铲除，而没有将红砖进行登记、移交给陈某某或采取保护措施不当，某县某镇政府应对该部分合法财产损失承担赔偿责任，但陈某某在收到《限期拆除通知书》后没有将红砖及时转移，也存在一定的过错，也应当对该部分物品的损失承担相应的责任，鉴于对红砖的价值双方均没有确凿的证据证明，故综合考虑原告、某县某镇政府双方的责任，本院酌情确定某县某镇政府应赔偿强制拆除行为造成陈某某红砖损失为1000元。对于陈某某主张卷闸门及木头的损失，因该部分物品属于房屋必要组成部分，不能认定为受法律保护的合法财产，对该部分物品的损失，本院依法不予支持。陈某某以其取得的《乡村建设规划许可证》主张建房存在对政府合理信赖利益的意见，根据《中华人民共和国土地管理法》第七十四条，《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区农村宅基地审批管理办法的通知》第三条第二款，《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条第三款、第四款，《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第三十八条的规定，农村村民建设住宅，对不属于使用原有宅基地建造住宅的需要由乡、镇人民政府报市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。如需要使用到农用地建设房屋，还需要办理农用地转用手续，并取得《农村宅基地建设用地批准通知书》。本案中，陈某某非涉案土地所属集体经济组织成员，向案外人购买土地建设住宅，在未取得《农村宅基地建设用地批准通知书》及未取得依法由市、县人民政府城乡规划主管部门核发的乡村建设规划许可证情况下，其自行建设的房屋，是其个人行为，不属于得到政府的许可，不存在政府信赖利益。陈某某该项主张于法无据，本院不予支持。

广西壮族自治区平南县人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第二款第一项，第七十六条，第三十八条第二款，《中华人民共和国国家赔偿法》第二条第一款，第四条第二项，第三十二条第一款，第三十六条第四项、第八项，《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第三十一条，第三十二条第四项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第四十七条第三款的规定，判决如下：

一、确认某县某镇政府某镇人民政府于2021年10月19日强制拆除陈某某房屋的行为违法；

二、某县某镇政府某镇人民政府赔偿陈某某红砖损失1000元及利息损失（该利息损失以1000元为计算基数，按照LPR从2021年10月19日计算至实际给付之日止，不计算复利）；

三、驳回陈某某的其他诉讼请求。

陈某某不服一审判决，提出上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。广西壮族自治区贵港市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

信赖利益保护原则是指行政相对人对行政机关作出的行政行为或承诺形成合理信赖，并且行政相对人基于此信赖实施了信赖行为，因此享有信赖利益，且这种利益值得被保护时，行政主体不得随意变更、撤销或者废止行政行为，如果在权衡信赖利益和公共利益后，确因公共利益的需要而需变更、撤销或者废止行政行为时，则必须对行政相对人受到的损害予以补偿或者赔偿。本案中，行政相对人在建设违法建筑过程中曾经获得被撤销的规划许可证，在获得规划许可证后建设的房屋是否享有信赖利益，是本案审理中最为关键的问题。

一、行政相对人主张保护信赖利益应具备的要件

一是有信赖的基础，即行政机关作出了一定的行为，包括作为、不作为以及承诺等，且该行政行为足以引起相对人对公权力的合理期待；二是相对人基于信赖基础（行政行为）有效存在，根据自身利益实施了特定的信赖行为，如果相对人在实施信赖行为前不知道信赖行政行为的存在，则其后实施的行为不属于信赖行为；三是相对人所形成的信赖利益值得保护，是“正当利益”，如果相对人是采取欺骗、贿赂等不正当手段获得的利益，则是不正当的信赖，法律不予保护。《中华人民共和国行政许可法》对信赖利益保护主要体现为第八

条和第六十九条的规定，其中第六十九条规定，行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定或超越法定职权作出准予行政许可决定的，作出行政许可决定的行政机关可以撤销行政许可，被许可人的合法权益受到损害的，行政机关应当依法给予赔偿；被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销，被许可人基于行政许可取得的利益不受保护。本案中，陈某某通过向非该集体经济组织成员的方某某非法购买获得涉案土地，虽然是基于信任某镇国规站颁发的《乡村建设规划证》而建设房屋，但《乡村建设规划证》是方某某通过贿赂时任某镇国规站的玉某某滥用、超越职权发放所得。虽然陈某某符合主张保护信赖利益的前两个要件，但是陈某某基于贿赂手段得到《乡村建设规划证》而建设的房屋属于不正当利益，法律不予保护。

二、行政机关与行政相对人混合过错情形下的信赖利益保护

对于损害的发生，在行政机关与行政相对人都有过错的情形下，判断相对人是否仍有信赖利益保护请求权，不是看行政行为是否违法，也不是看行政机关工作人员是否有故意或过失，而是看最终形成的利益是否是“正当利益”。如果是因为相对人的故意或重大过失导致获得的信赖利益不值得被保护的，则相对人的信赖利益保护请求权不能成立；如果是因为相对人故意或重大过失以外的错误获得信赖利益导致的损害后果，不影响相对人信赖利益保护请求权的成立，但是会影响相对人根据信赖利益保护请求行政机关补偿或赔偿数额的比例，相对人要对因其过错造成损害承担相应的责任。本案中，根据某镇规划，陈某某购买的涉案土地是农用地，属于限制建设区，陈某某要想获得《乡村建设规划证》应办理农用地转批手续并由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发，某镇国规站是无权核发的。陈某某辩称不知道该证是方某某行贿获取的，基于对该证的信任建设的房屋应受保护，但陈某某是和方某某通过违法买卖土地的方式获得涉案土地，陈某某没有填写提交任何申请材料则能直接获取《乡村建设规划证》，且《乡村建设规划证》未办理其他用地审批手续，与生活常理不符，可以推测陈某某应当知道方某某是通过不正当手段获取的《乡村建设

规划证》。如果方某某没有行贿、玉某某没有滥用职权，某镇国规站是不可能给陈某某发放《乡村建设规划证》的，所以因行贿获得的《乡村建设规划证》不值得被保护，自然资源局撤销该证也无须承担补偿责任，陈某某基于该证建设的违法建筑也不应得到保护，某镇政府在拆除违法建筑时无须补偿。但某镇政府在拆除违法建筑的过程中仍应注意保护陈某某的合法财产，对违法建筑旁尚未使用的红砖没有予以登记、清空并妥善处置导致灭失，某镇政府应当对陈某某灭失的合法财产承担赔偿责任。

编写人：广西壮族自治区平南县人民法院 吴明燕

已为后续具体行为吸收的前行政强制措施不具有可诉性

——郑某诉某区交警大队行政强制措施案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市武昌区人民法院（2023）鄂0106行初289号行政裁定书

2. 案由：行政强制措施纠纷

3. 当事人

原告：郑某

被告：某区交警大队

【基本案情】

2023年6月9日1时36分，郑某饮酒后驾驶机动车，被某区交警大队查获，现场酒精呼气测试结果为48毫克/100毫升，郑某当场签字确认。

当日，某区交警大队采取行政强制措施：扣押机动车驾驶证、拖移机动车、

检验血液。但某区交警大队未实施拖移机动车及检验血液的强制措施，仅扣押了郑某的机动车驾驶证。

2023年11月2日，某区交警大队以郑某前述违法行为属于在一个记分周期内累计达到12分的违法行为，采取行政强制措施：扣押机动车驾驶证。

2023年11月2日，某区交警大队作出行政处罚决定书，以郑某的前述违法行为，决定处以：郑某罚款2000元；暂扣机动车驾驶证6个月。

【案件焦点】

郑某原诉请撤销某区交警大队作出的扣留机动车驾驶证的行政强制措施，是否就该行政强制措施行为合法进行审查。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市武昌区人民法院经审理认为：本案系因郑某不服某区交警大队扣押机动车驾驶证的行政强制措施而提起的诉讼，在诉讼过程中，郑某提出新的诉讼请求，其实质是请求将后续的行政强制措施和行政处罚决定书与之前的行政强制措施的三个具体行政行为进行合并审理。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第七十条的规定，起诉状副本送达被告后，原告提出新的诉讼请求的，人民法院不予准许，但有正当理由的除外。据此，应对郑某提出的新的诉讼请求，是否具有正当理由，进行分析判断郑某原诉请撤销某区交警大队作出的扣留机动车驾驶证的行政强制措施，由于该行政强制措施已经被后续案涉行政处罚所吸收，本院已不必就该行政强制措施行为是否合法进行审查。而郑某提出的新的诉讼请求，不符合合并审理法定条件，应当另案起诉。经本院向郑某进行指导和释明，郑某坚持变更、增加诉请并要求合并一案审理，依法应裁定驳回其起诉。

湖北省武汉市武昌区人民法院裁定如下：

驳回原告郑某的起诉。

裁定后，双方当事人均未上诉，本裁定现已生效。

【法官后语】

首先，不是每种行政强制措施都具有可诉性。行政强制措施是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施的暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。一个特定的行政强制措施是否具有可诉性，取决于它是否是一个独立完整的已经成立的具体行政行为及其与相对人权益的关系。《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条第一款第二项虽然明确将行政强制措施纳入人民法院的受案范围，但并不表明任何形态的行政强制措施都具有可诉性。某一具体的行政强制措施是否具有可诉性，取决于该行政强制措施是否达到了自身的独立性和成熟性，取决于它与相对人权益的关系。行政强制措施的独立性和成熟性，是指行政强制措施作为一个独立完整的具体行政行为是否已经成立。而行政强制措施与相对人权益的关系则是法律上的利害关系，即行政强制措施的采取是否影响或可能影响相对人的合法权益。根据行政强制措施实施带来结果的不同，其可诉性有所不同。一般来说，行政主体实施了行政强制措施，紧随其后又实施了行政处罚或其他具体行政行为，这时的行政强制措施就与紧随其后的具体行政行为形成了先行后续、无法割舍的关系。在多数情况下，这种行政强制措施的实际作用就是保障或辅助后续的具体行政行为的作出。在后续的具体行政行为作出后，行政强制措施应理解为已被具体行政行为所吸收，而不再具有独立的意义。另一种情况是行政主体采取了行政强制措施以后，因种种条件和原因，没有必要、也不再实施后续的具体行政行为。这时的行政强制措施就成为一个直接影响相对人权益的、独立、完整的具体行政行为。产生第一种结果的行政强制措施因其不具有独立性和完整性，而没有可诉性，相对人对这种强制措施的异议和权利请求，可以归并入对后续具体行政行为的异议和权利请求之中。产生第二种结果的行政强制措施，在特定的场合和特定的行政活动中，是独立完整并且是唯一的，对相对人权益的影响也是独立和直接的。因而这种行政强制措施具有可诉性。本案中，根据上述分析所得出的结论即为：在先的行政强制措施旨在制止违法行为、避免危害发

生、控制危险扩大，目的不是为行政处罚收集证据并防止证据损毁，该扣押机动车驾驶证的强制措施已经被后续行政强制措施和行政处罚决定书吸收，已经不是一个独立完整的已经成立的具体行政行为，应归并入对后续案涉行政处罚这一具体行政行为的异议和权利请求之中。

其次，《最高人民法院第一巡回法庭关于行政审判法律适用若干问题的会议纪要》就“起诉人同时起诉多个行政行为的，人民法院应当如何处理？”指出：“起诉人同时对多个行政行为提起诉讼，人民法院应当分别对每一个行政行为是否符合法定起诉条件进行审查。起诉人起诉的多个行政行为系关联性行为，均符合法定起诉条件的，人民法院应当合并一案立案审理。人民法院认为起诉人起诉的多个行政行为不宜合并一案审理的，应当向起诉人进行指导和释明，要求起诉人分别起诉。起诉人坚持一并起诉的，人民法院可以根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十九条第一款第十项规定，以起诉不符合合并审理法定条件为由，裁定驳回起诉。”即每一个行政行为均构成一个独立的诉，人民法院应当分别对每一个被诉行政行为是否符合起诉条件分别进行审查，作出判断。虽然合并审理是节约诉讼成本、实质化解争议的有效方式，但是否应当合并审理，是法定的起诉条件之一，对于不符合合并审理法定条件的，应当分别起诉。如前所述，在先的行政强制措施并不是作出案涉行政处罚的法定先置程序条件，其是否合法不直接影响作出案涉行政处罚的证据是否充分合法，之间不具有直接因果关系，即该行政强制措施并不是法律规定的行政处罚所必须遵守的程序，其不具备行政处罚的程序目的，不符合合并审理法定条件。

编写人：湖北省武汉市武昌区人民法院 王勇睿

强制拆除无需等待执行决定救济期限届满即可实施

—— 某公司诉某区执法局强制拆除房屋案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省苏州市中级人民法院(2023)苏05行终503号行政判决书

2. 案由：强制拆除房屋纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某公司

被告(被上诉人): 某区执法局

【基本案情】

2019年9月11日, 某区执法局作出处罚决定, 查明某公司未取得建设工程规划许可证在厂区红线范围内存在15处(项)建筑, 故责令限期十五日内自行拆除。该处罚决定经行政复议、行政诉讼后被维持。某区执法局经催告、责成后于2021年12月2日作出强制执行决定, 并于2021年12月7日至13日实施拆除行为。某公司不服强制执行决定申请行政复议, 复议机关认为某公司按期邮寄提交书面陈述、申辩意见, 某区执法局以未提出陈述、申辩据此作出强制执行决定, 违反法定程序, 确认强制执行决定违法, 后双方均未向法院起诉。现某公司提起诉讼, 要求确认某区执法局实施强制拆除行为违法。

【案件焦点】

1. 依照《中华人民共和国行政强制法》第四十四条规定, 行政机关是否必

须在强制执行决定法定救济期限届满后方可实施拆除行为；2. 已被行政复议程序确认违法的强制执行决定能否作为强制拆除行为的依据；3. 强制拆除行为程序合法性的具体审查标准。

【法院裁判要旨】

江苏省苏州市吴中区人民法院经审理认为：根据相关规定，某区执法局具有对案涉违法建设实施强制拆除措施的职权。关于强制拆除程序是否合法。根据《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国城乡规划法》相关规定，对于违法建设，行政机关应当依次履行调查违法事实、处罚告知、作出处罚决定、催告、作出强制执行决定、公告等手续和程序后，才能实施强制拆除。本案中，处罚决定作出后，经行政复议及行政诉讼该决定被依法予以维持。某区执法局经催告、人民政府责成，作出强制执行决定，并依法进行送达、公告，后实施拆除，程序合法。强制执行决定被行政复议决定确认违法但未被撤销，故强制执行决定可以作为案涉强制拆除行为的有效依据。某区执法局实施拆除时对建筑内物品搬运至指定地点，拆除过程经公证部门现场公证，未扩大拆除范围和违法采取措施，合法性应予确认。

关于某公司认为某区执法局自2021年11月29日起实施拆除行为，且拆除范围涉及非法占用的2143平方米土地上建筑及其他建筑。但某区执法局已提供某区管委会的批复及某街道办事处《公告》，证明2021年11月29日至12月6日系某街道办事处实施的拆除非法占用2143平方米土地上建筑的行为。故，某公司要求对拆除非法占用2143平方米土地上建筑的行为确认违法的诉请本案不予理涉。

关于是否应在强制执行决定的法定救济期限届满后方可实施拆除行为。首先，《中华人民共和国行政强制法》第四十四条规定中“不申请行政复议或者提起行政诉讼”所具体指向的行政行为，根据文义解释应为该条款前句中表述的“限期当事人自行拆除”这一法律行为。其次，对强制执行决定的合法性审查无法否定处罚决定对案涉违法建设合法性作出的认定以及创设的拆除义务。最后，对《中华人民共和国行政强制法》第四十四条规定的适用，需要受到该

法总则第一条立法目的的限定。本案中，将处罚决定的救济期限届满，作为强制执行程序的开始，则能够兼顾到依法及时履职、公共利益维护和相对人权益保障三方面价值。故，某区执法局未在强制执行决定的法定救济期限届满后实施拆除行为，并无不当。综上，某区执法局拆除案涉违法建设的行为符合法律规定，某公司诉讼请求缺乏事实与法律依据，不应支持。

江苏省苏州市吴中区人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，作出如下判决：

驳回原告某公司的全部诉讼请求。

判决作出后，某公司提出上诉。

江苏省苏州市中级人民法院认为某公司的上诉请求不能成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。

江苏省苏州市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要的争议焦点在于强制拆除是否需要等待执行决定行政复议及诉讼期限届满才能实施，即是否存在强制拆除行为程序违法，但本案从行政处罚、强制执行决定、强制措施历经数次复议及诉讼，完整地展现了从违建查处到强制拆除的执法过程，具有一定的裁判示范意义。

第一，依照《中华人民共和国行政强制法》第四十四条规定，行政机关是否必须在强制执行决定法定救济期限届满后方可实施拆除行为。行政强制法对行政强制执行规定了严格的程序，在遵循程序法定原则时，也应当兼顾行政效率、相对人权益保障、公共利益维护等多种法律价值。从文义上看，《中华人民共和国行政强制法》第四十四条中“不申请行政复议或者提起行政诉讼”所省略规定的内容，系指向前句中表述的“限期当事人自行拆除”的法律行为。“限期当事人自行拆除”应当是认定行政相对人存在违法建设行为、需要负担限期拆除建筑物法律后果的法律行为，与强制执行决定不同。“强制执行决定”

本身既不对建设行为合法性作出认定，也不创设具体拆除义务。如果“限期当事人自行拆除”因救济期限届满或者经人民法院确认合法而具备实质存续力，那么相对人限期拆除建筑物的负担就是确定的，此时无法通过对“强制执行决定”的合法性审查，否定“限期当事人自行拆除”所确定的权利义务关系。即便行政机关实施强制执行时扩大执行范围或者违法采取措施，通过对具体实施的强制拆除这一事实行为的审查和相应行政赔偿法律程序，使相对人获得救济更为适当。《中华人民共和国行政强制法》第四十四条的主要功能在于通过对相对人行政复议和诉讼权利的保障，促进行政机关规范行使强制执行权，体现对相对人权益的尊重和保护。但是，法律程序控制的目的在于强制执行权的依法规范行使，而非要求行政机关迟延或者放弃行使职权。如果行政机关需等待相对人穷尽包括“强制执行决定”在内所有环节行政行为的救济之后执行，因迁延日久，不利于体现对违法行为查处和公共利益恢复的及时性，并有损行政权威。将具体创设权利义务关系的“限期当事人自行拆除”即处罚决定的救济期限届满，作为强制执行程序的开始，则能够兼顾到依法及时履职、公共利益维护和相对人权益保障三个方面价值。

第二，关于已被行政复议程序确认违法的强制执行决定能否作为强制拆除行为的依据。行政行为具有公定力，除因严重违法而自始无效外，在未经法定机关和法定程序撤销或者变更之前，都应具有效力。强制拆除行为是具体实施强制执行决定的事实行为，强制执行决定及强制拆除行为二者均为独立可诉的行政行为，并无基于公民权利救济的需要而突破行政行为公定性效力进行违法性继承之必要。且本案中强制执行决定确认违法理由为程序违法，即并未从实体上进行否认，故强制执行决定可以作为案涉强制拆除行为的有效依据。

编写人：江苏省苏州市吴中区人民法院 赵纯碧

人民法院应当对已纳入征收范围内的房屋实施的 强制拆除行为进行从严实体审查

—— 杨某诉某区城市管理执法局等强制拆除房屋或设施案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省宜昌市伍家岗区人民法院(2023)鄂0503行初6号行政判决书

2. 案由：强制拆除房屋或设施纠纷

3. 当事人

原告：杨某

被告：某区城市管理执法局、某区住房和城乡建设局、某区某乡人民政府

【基本案情】

杨某系某区某乡某村村民。国土部门颁发的《用地许可证》载明其经审核同意可占用空闲地20平方米建房。2021年4月15日，某区城市管理执法局对杨某建设的房屋进行现场检查，认为杨某存在未经规划许可审批建房，并对杨某无证建房一案立案审批。2021年4月19日，某区城市管理执法局作出《当事人权利告知书》，责令杨某限期拆除违法建设的房屋。

2021年6月17日，某市城(乡)燃气安全生产专业委员会办公室作出《某市城(乡)燃气隐患线索移交书》，载明杨某案涉房屋所在位置处于该移交书后附的《城区燃气管道占压隐患汇总》中“某路建行旁3处占压中压A管道”。2021年6月29日，某区住房和城乡建设局向杨某发出《限期整改通知书》，责令其拆除占压燃气管道的违法建(构)筑物，逾期未拆除或拆除不彻

底的,将由区城管局及街乡城管执法中心进行强制拆除。

2021年7月2日,某区住房和城乡建设局收到宜昌中燃城市燃气发展有限公司发出的《紧急联系函》,表明杨某案涉房屋所处位置燃气已局部泄漏,需紧急处理。当日,杨某房屋被拆除。

杨某认为其房屋被纳入征收范围,在未达成拆迁安置补偿协议的情况下,三被告实施强制拆除系以拆违代拆迁。某区住房和城乡建设局陈述系某区城市管理执法局出于公共安全考量拆除违法建筑。某区城市管理执法局陈述拆除行为系某区住房和城乡建设局实施,其在现场维持秩序,配合某区住房和城乡建设局完成消危行动。某区某乡人民政府辩称其不具有强制拆除权力,非强制拆除主体。

【案件焦点】

1. 强制拆除行为的性质;2. 实施强制拆除行为的主体认定;3. 强制拆除行为是否合法。

【法院裁判要旨】

湖北省宜昌市伍家岗区人民法院经审理认为:依据规定,某区住房和城乡建设局作为其辖区内的燃气管理部门,行使燃气使用安全状况监督检查权具有法律依据。某区住房和城乡建设局提供的《某市城(乡)燃气隐患线索移交书》与《紧急联系函》并不足以证明杨某房屋占压的管道已出现局部泄漏,亦不足以证明该局主动采取强制拆除措施的现实紧迫性和必要性。因此,可以认定该局组织实施了强制拆除行政行为,且作出强制拆除行政行为证据不足,行政行为应予撤销。依据《中华人民共和国城乡规划法》相关规定,某区城市管理执法局有权行使辖区内的城市规划管理方面法律、法规和规章规定的行政执法及处罚权。经审理查明,该局仅对杨某作出《当事人权利告知书》,据此可以认定该局对杨某案涉违法建筑有治理拆除的意思表示。该局辩称其在拆除现场系配合某区住房和城乡建设局顺利实施消危行动,并未实施强制拆除,但就该主张并未提供证据予以证明,且该局所举证据亦不能证明强制拆除行为的合

法性。因此，可以认定该局作出了强制拆除行政行为，且未履行法定程序。杨某提交的证据不足以证明某区某乡人民政府实施了拆除涉案房屋的行为。

综上，可以认定本案强制拆除行为系某区城市管理执法局、某区住房和城乡建设局共同实施，且强拆行政行为违法，应予撤销。鉴于案涉房屋已在庭审前全部拆除，案涉行政行为不具有可撤销的内容，故应确认违法。

湖北省宜昌市伍家岗区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第二款之规定，判决如下：

确认某区住房和城乡建设局、某区城市管理执法局于2021年7月2日强制拆除杨某房屋的行政行为违法。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

本案系行政征收中因强制拆除房屋而引起的纠纷，当事人无法识别实施强制拆除主体的人员身份，强制拆除后也无任何行政主体主动承担强制拆除责任，如何明确强制拆除行为的主体系本案争议焦点。该案涉及某区城市管理执法局、某区住房和城乡建设局、某区某乡人民政府多个行政执法机关，涵盖行政征收、拆除违法建筑、解危拆危等多种情形，体现了行政权行使过程的多样性以及行政组织系统内部关系的复杂性。

一、强制拆除行为主体的认定

强制拆除建筑行为因具有强制性，极易激化行政机关与行政相对人的矛盾。人民法院在审查行政机关的强制拆除行为时，应坚持严格、审慎的原则进行全面合法性审查。强制拆除行为主体认定依法律行为和实施行为的不同而采取不同的认定方式。对于法律行为，因存在明确的法律规定的前置性程序行为，出具法律文书或者对外发生法律效力决定为被告。对于事实行为，因无法辨明谁具体实施了强制拆除行为，通常采取推定行为主体的方式。多个行政机关均出现在拆除现场，但均否认实施了强制拆除行为，宜采用推定行为主体的方式确认强拆主体，结合行政机关对案涉建筑前期有无治理行为，有无拆除意思表示，理由是否充分等情形，综合判定强拆主体。本案从职权法定、程序法定等

原则，同时考虑行政机关事实上参与组织实施的程度，对强拆行为的责任主体进行多维度分析并认定。

二、强制拆除行为合法性审查

对于已纳入征收范围内的房屋，行政机关实施的强制拆除行为，应严格遵守法定程序，有充分的事实依据和证据，适用法律正确，衡平公益和私益，尤其是以解危形式强制拆除的，更应充分提供作出强制拆除行为的依据，恰当适用比例原则，不得以公共利益为由衍生出一系列规避法定程序的新举措。人民法院在审查此类强制拆除行为时，应从严审查，以实体审查为原则，兼顾程序审查。

人民法院通过确认违法判决明确告知行政机关应当遵循合法化、规范化的征收程序，不能以拆危解危、抢急救险等危害公共安全的情形跨越法定的征收程序，人民法院亦应谨慎审查行政执法机关在取舍公共利益与私人利益时是否遵循了比例原则，全面审查行政行为的合法性，从而作出合法合理的司法判断，引导行政机关“严格、规范、公正、文明”执法，体现出以人为本，尊重群众主体地位的制度价值。

编写人：湖北省宜昌市伍家岗区人民法院 孙晓梦

行政机关不得以扣促罚， 以相对人未缴纳罚款为由超期扣押财物

—— 罗某诉某镇政府行政强制措施及行政赔偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广州铁路运输中级法院(2023)粤71行终2515号行政判决书

2. 案由：行政强制措施及行政赔偿纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 罗某

被告(上诉人): 某镇政府

第三人: 某运输公司

【基本案情】

2021年1月4日, 罗某将其购买的重型自卸货车挂靠并登记在某运输公司名下运营。2022年5月19日, 某镇政府发现某运输公司司机何某驾驶该货车运输建筑废弃物时车辆不整洁、不密闭装载。因何某现场拒不改正上述违法行为, 某镇政府当场向何某作出《行政强制措施决定》, 决定自2022年5月19日起至6月18日止扣押该货车。

2022年7月17日, 某镇政府通知某运输公司解除扣押措施。2022年9月1日, 某镇政府向某运输公司作出罚款通知书, 要求其限期缴交16000元罚款。同日, 某运输公司缴纳了罚款, 何某出具说明, 称因老板没钱一直没有处理, 直到2022年8月22日才处理, 因自身原因暂时不取车。2022年9月5日, 某镇政府出具车辆放行条, 何某取回案涉货车。

评估公司受某运输公司委托, 评估出根据车辆租赁价格, 案涉货车2022年6月18日至9月5日的停运费用为99000元。罗某不服超期扣押行为, 诉至法院, 请求确认某镇政府从2022年6月18日至9月5日扣押货车的行政行为违法, 并赔偿其车辆停运损失99000元、评估费用3450元。

诉讼中, 某镇政府提供其工作人员2022年5月25日、6月22日、6月23日与何某的通信记录, 主张其多次联系某运输公司领回被扣押的车辆。罗某称某镇政府并非要求其取回车辆, 而是通知缴纳罚款后方可取回车辆。

【案件焦点】

1. 罗某是否具有提起行政诉讼主体资格; 2. 某镇政府扣押车辆行为是否合法; 3. 赔偿金额和损失如何认定。

【法院裁判要旨】

广州铁路运输法院经审理认为：某运输公司不出庭应诉也未反驳罗某诉请，罗某是案涉车辆实际使用人，被诉行政行为可能影响罗某合法权益，其具有提起行政诉讼的主体资格。

案涉车辆因运输建筑废弃物存在车辆不整洁、不密闭装载等行为被扣押，如该行为成立，某镇政府无继续核查的需要。且该车是较新货运车辆，罗某应不存在可取回而不取回的可能。结合何某说明、罗某陈述、放行条等，可以认定某镇政府2022年7月17日解除扣押，但罗某因资金原因，于2022年9月1日缴纳罚款，2022年9月5日取回车辆的法律事实。某镇政府不能以罗某未及时缴纳罚款为由长期扣押车辆，其2022年6月18日至9月5日扣押车辆的行为应当确认违法。

2022年6月18日至7月16日超期扣押，某镇政府应赔偿罗某直接损失；2022年7月17日至9月5日超期扣押，因双方均存在过错，应根据过错确定赔偿责任。罗某主张的租赁损失为可期待收入，并非直接损失，但考虑车辆为货运车辆，被扣押造成罗某营运损失，根据双方过错和责任大小，结合车辆折旧因素，酌情认定罗某损失为12000元。评估费不属于国家赔偿范围。

广州铁路运输法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第二款第一项、《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第三十二条规定，判决如下：

一、确认某镇政府于2022年6月18日至9月5日超期扣押某重型自卸货车的行政行为违法；

二、于判决生效之日起七日内，某镇政府赔偿罗某经济损失12000元；

三、驳回罗某的其他赔偿请求。

某镇政府不服，提出上诉。

广州铁路运输中级法院经审理认为：某镇政府扣押期间未作出行政处理或延长扣押期限，未证明有正当理由需继续扣押，也未证明法律法规对扣押期限另有规定，超期扣押缺乏法律依据，违反法定程序。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。

广州铁路运输中级法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、挂靠车辆实际权利人不服行政机关就挂靠车辆违法行为作出的行政行为，有权提起行政诉讼

车辆挂靠 in 货运行业普遍存在，一些货车车主因自身资质等原因，无法办理车辆营运证，为实现车辆最大经济价值，车主就会将个人购买的车辆登记在具有道路运输经营资质的企业名下并以企业名义运营车辆。但是车辆仍由实际权利人控制、运营，被挂靠企业仅收取一定管理费，并不过多地参与车辆管理。

挂靠车辆运营时出现行政违法行为，因被挂靠企业为登记车主，行政机关多数将被挂靠企业列为行政相对人，而挂靠经营合同经常都约定挂靠方（车辆实际权利人）承担由此产生的法律后果。故，若被挂靠企业在执法、司法程序中做权利的沉睡者，挂靠方的合法权利可能就无法得到救济。法院认定挂靠方与该种行政行为有利害关系，赋予其原告资格，有利于保障挂靠方合法权益。

二、行政机关不得以扣促罚，以相对人未缴纳罚款为由超期扣押财物

行政机关扣押财物限制了行政相对人自主支配、使用财产的权利，为负担行政行为，其行使该职权必须符合适当性原则且遵循法定程序。根据《中华人民共和国行政强制法》规定，行政机关扣押财物是为了制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等目的而实施。由此可见，扣押财物应以实现行政管理目的、维护行政秩序为价值追求，而非为了确保行政处罚执行到位。行政强制法严格规定扣押期限，可以防止行政机关扣押过久而损害财物的价值、影响经营活动及相对人权利长期处于不稳定状态。

在扣押期间，行政机关要及时查清事实，在法定期限内作出行政处理决定。若扣押期限届满或无继续扣押的必要，行政机关应依法及时解除扣押，不得无正当理由超期扣押。但是，有些行政机关基于执法成本等考虑，以扣促罚，要求行政相对人履行行政处罚义务才解除扣押措施。该行为违反了行政强制法第

五条规定的行政强制适当性原则，势必侵害行政相对人的合法财产权，属于滥用职权行为，行政机关应当承担由此产生的行政赔偿责任。

行政诉讼设立的目的是保护公民、法人和其他组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权。在行政相对人能初步证明行政机关怠于解除扣押而行政机关无法提供反证的情况下，法院支持行政相对人的主张，有利于规制行政机关滥用扣押权，更好地维护相对人合法权利。本案中，案涉车辆违法事实清楚，亦明显无须对车辆检测、鉴定等继续核查必要。案涉车辆为较新货车，某镇政府在当事人交纳罚款后才将车辆放行。根据常识和公众的趋利避害心理，罗某不可能取回车辆而不取回。因此，可以推定某镇政府是因罗某未交纳罚款而超期扣押车辆，该行为违反了行政强制法规定，应当确认违法。

不可否认，行政相对人在财物被解除扣押后迅速转移财产，导致行政处罚无法立即执行的情况也时有发生。出现这种行政相对人逾期不履行行政处罚决定的情形，行政机关应当依照《中华人民共和国行政处罚法》、行政强制法的规定，采取加处罚款、申请法院强制执行等合法手段，而非滥用扣押权。

编写人：广州铁路运输法院 钟燕秋 黄丽丽

行政机关拆除被征收人依协议 腾退的房屋不属于行政强制行为

——王某某、吴某某诉某县人民政府某街道办事处强制拆除房屋案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省丽水市中级人民法院（2023）浙11行终65号行政判决书

2. 案由：强制拆除房屋纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某某、吴某某

被告(被上诉人):某县人民政府某街道办事处(以下简称某街道办事处)

【基本案情】

原告王某某、吴某某在某县拥有房产一处,在某区块城中村改造项目征收红线范围内。2022年7月,被告某街道与两名原告签订了《某县征收集体所有土地房屋补偿安置协议书》(住宅·产权调换),协议约定:“选本项目房屋搬迁腾空截止日(另行公布)前搬迁腾空完毕,并交由甲方验收封管……在规定的期限内,本项目签约率达到95%(含)以上、且土地征收申请经依法批准并公告之日起协议生效……”2022年7月16日,某县人民政府发布《通告》,该城中村改造项目房屋征收补偿协议签约率达到98.56%,协议生效。2022年8月23日,浙江省人民政府批准征收某县某区块城中村改造项目范围内的集体土地。2022年8月29日,某县人民政府发布《土地征收公告》。2022年10月7日,由原告王某某签名向城中村改造项目指挥部提交《腾空验收申请》,表示被征收房屋全部腾空完毕,并自愿将被征收房屋交予政府依法处理,请组织验收。同日,原告王某某在《搬迁腾空验收单》上签名,确认腾空房屋,面交钥匙,验收合格。2022年10月28日,某街道在中国农业银行某县支行分别以吴某某、王某某名义开列存单形式各支付征收补偿款574964.29元,共计1149928.58元。2022年10月29日,以手机短信形式告知补偿款已发放。2022年10月31日,被告组织拆迁公司将案涉房屋进行了全部拆除。嗣后,两名原告以非自愿签订协议、尚未与征收部门就安置补偿事宜达成一致、强制拆除房屋违法为由,于2022年11月诉至法院,要求确认某街道强制拆除房屋行为违法。

【案件焦点】

拆除房屋行为是行政强制拆除行为,还是履行协议后的有权处置行为。

【法院裁判要旨】

浙江省丽水市青田县人民法院经审理认为：本案系两名原告不服被告因征收于2022年10月31日拆除案涉房屋而提起的诉讼。争议焦点为拆除房屋行为是属于行政强制拆除行为，还是履行协议腾空交付房屋后的处置行为。两名原告与被告签订了《某县征收集体所有土地房屋补偿安置协议书》，2022年7月15日该征收区块签约率达到98.56%。2022年8月23日，浙江省人民政府批准征收该区块项目范围内的集体土地。至此双方签订的《某县征收集体所有土地房屋补偿安置协议书》约定条件已成就，协议已生效。王某某作为案涉房屋共有人及协议签订人有权代表征收户向被告提交《腾空验收申请》。根据腾空验收申请和搬迁腾空验收单的记载内容，表示王某某已自愿将被征收的案涉房屋腾空并交付被告。被告经验收合格后接收了房屋，在交付征收补偿款后可自行处分拆除。被告以开列存单形式支付征收补偿款后，组织拆迁公司对涉案房屋进行拆除，系履行协议腾空交付房屋后的处置行为，拆除行为合法，该行为不具有行政强制性性质，无须以《中华人民共和国行政强制法》为依据，也不需要遵循《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第二十四条规定的程序执行。两名原告主张被告拆除房屋行为违法，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

浙江省丽水市青田县人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回原告王某某、吴某某的诉讼请求。

王某某、吴某某不服一审判决，提出上诉。

浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

以行政协议形式推进征收工作，具备提高征收效率、实现合理补偿、促进

社会和谐、增强政府公信力等诸多优势，在实践中得到广泛应用。与此同时，因征收利益巨大，被征收人签订征收补偿安置协议又反悔时有发生，本案即是被征收人签订协议并腾空交房后，不同意行政机关拆除房屋引发的纠纷。对此类案件的审查，因前置征收行为是其基础性行为，基于全面合法性审查原则，还应对征收行为的合法性进行全面审查，因此，判断是否属强拆宜使用反向排除认定。

1. 房屋征收安置补偿协议是否已经生效。征收安置补偿决定或生效的安置补偿协议是征收部门拆除房屋的合法性基础。在此类案件中，若协议未生效，则征收行为失去合法性，应认定拆除房屋行为具有行政强制属性。因此，法院应首先查明安置补偿协议是否已经生效，其隐含两个前提：一是所签订的协议成立，即被征收人与征收部门平等协商后，达成合意签订安置补偿协议，且不存在受胁迫、欺诈、乘人之危、显失公平及重大误解等可撤销或无效之情形；二是协议已经成就生效条件，即旧城中改造区块被征收房签约率达到最低法定要求。

2. 被征收人是否自愿腾空交房。被征收人自愿签订安置补偿协议和自愿腾空交付房屋是构成被征收自愿性的基础，是判断行政机关后续拆除行为是否属于强制拆除的核心要点。在审查被征收人是否自愿腾空交房时，法院应从以下三个方面严格把握：(1)征收部门或第三方不存在使用强迫、诱骗等行为，被征收人自愿搬出房屋。(2)书面签订确认自愿交付房屋，实践中多为在房屋腾空交付验收单上签字。(3)房屋内已无人实际居住，此实际居住应以生活居住为标准，而非因对抗而临时性返回暂住。

3. 征收行为是否符合“先补偿、后搬迁”原则。“先补偿、后搬迁”原则是行政机关依法征收所必须遵循的原则，它保障了被征收人在搬迁之前获得合理的补偿，可以防止行政机关权利滥用和违法征收。行政机关在此应举证是否已经足额支付了约定的安置补偿款、落实了临时安置过渡措施，否则，应认定行政机关征收行为违法。

4. 房屋拆除行为的依据。房屋拆除行为的依据是判断行政机关是否属于强

制拆除的关键要素。在查明行政行为合法的基础上，法院应对行政机关拆除房屋的依据进行审查，根据行政诉讼“举证倒置”原则，行政机关应综合举证证明其拆除行为是被征收人履行安置补偿协议、自愿腾空交付并支付补偿后的依约拆除。否则，即使前置征收行为合法，但未作为房屋拆除依据的，法院应当依照《中华人民共和国行政强制法》有关规定对其行为进行审查。

编写人：浙江省丽水市青田县人民法院 郭康宁

三、行政许可

20

农村宅基地审批行政行为对相邻权不产生直接影响，
相邻权人不具有提起行政诉讼的主体资格

——李某甲诉某镇政府农村宅基地审批案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08行终146号行政裁定书

2. 案由：农村宅基地审批纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):李某甲

被告(被上诉人):某镇政府

第三人：李某乙

【基本案情】

根据第三人李某乙的住宅用地申请，被告某镇政府于2022年4月8日作出《农村宅基地批准书》，批准第三人用地面积150平方米，其中房基占地135.71平方米，土地所有权人为李某乙，土地用途为宅基地，土地坐落为某镇某村某屯xx号。四至为东至李某甲私宅，南至李某丙私宅，西至李某丁私宅，北至卢

